

370
trescientos
setenta

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACIÓN IMPERIUM"

EXPEDIENTE N° 005-2023

CONSORCIO SUPERVISOR G y M
(Demandante)

VS.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUÁCAR
(Demandada)

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

Arbitro Único
Abog. Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza

Secretaria Arbitral
Abog. Gabriela Lucero Echevarría Tafur

Huánuco, 22 de diciembre del 2023.

RESOLUCIÓN N°

Huánuco, 19 de diciembre de 2023.

VISTOS: El expediente Arbitral.

1. DATOS GENERALES Y ABREVIATURAS

DATOS GENERALES:

Demandante : Consorcio Supervisor G y M
: RUC N° 20609666065

Demandada : Municipalidad Distrital de Huácar
: RUC N° 20189021764

Contrato : Contrato de Supervisión de Obra N° 001-2022-MDH-A de fecha 02 de febrero de 2022, para la Ejecución del Servicio de Supervisión de la Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DE LA MICRO RED HUÁCAR, DISTRITO DE HUÁCAR-AMBO-HUÁNUCO".

Monto del contrato : S/ 1'994,740.00 (Un Millón Novecientos Noventa y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta con 00/100 Soles).

Fecha de convocatoria : 16 de noviembre de 2021.

Fecha de firma de contrato: 02 de febrero de 2022

Inicio del arbitraje : 17 de agosto de 2023

Tipo de arbitraje : Institucional, Nacional y de Derecho

Controversias relacionadas a las siguientes materias:

- Resolución de Contrato
- Penalidades
- Pago de intereses.
- Condena de costas y costos arbitrales.

ABREVIATURAS:

Centro: Centro de Arbitraje Nacional e Internacional "Corporación Imperium".

368
torres
resenta y ocho

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
"CORPORACIÓN IMPERIUM"
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

EXPEDIENTE N° 005-2023
LAUDO ARBITRAL DE DERECHO
ARBITRO ÚNICO: HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA
DEMANDANTE: CONSORCIO SUPERVISOR G y M
DEMANDADA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUÁCAR

Contrato: Contrato de Supervisión de Obra N° 001-2022-MDH-A de fecha 02 de febrero de 2022, para la Ejecución del Servicio de Supervisión de la Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DE LA MICRO RED HUÁCAR, DISTRITO DE HUÁCAR-AMBO-HUÁNUCO".

COD: Cuaderno de Obra Digital

El Contratista o el Demandante: Consorcio Supervisor G y M

La Entidad o la Demandada: Municipalidad Distrital de Huácar

Las partes: Conjuntamente el Demandante y la Demandada.

LCE: Ley N° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado" modificada con Decreto Legislativo N° 1444.

Ley de Arbitraje: Decreto Legislativo N° 1071 que norma el arbitraje.

LPAG: Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444.

Proceso de Selección: Concurso Público N° 001-2021-MDH/CS, correspondiente a la contratación del servicio de consultoría de obra para la Supervisión de la Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DE LA MICRO RED HUÁCAR, DISTRITO DE HUÁCAR-AMBO-HUÁNUCO".

El Reglamento: Reglamento del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional "Corporación Imperium".

RLCE: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo N° 844-2018-EF modificada con Decreto Supremo N° 162-2021-EF.

MARCO INTRODUCTORIO:

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN

En la ciudad de Huánuco a los veinte siete días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023), la Árbitro Único, luego de llevar a cabo las actuaciones arbitrales en respeto riguroso del debido proceso y la igualdad de las partes, de conformidad con la ley y las normas establecidas por las partes, habiendo escuchado sus argumentos sobre las pretensiones planteadas en la demanda y los puntos controvertidos fijados en este arbitraje, ha realizado un análisis sobre todo lo debatido y los medios probatorios aportados, por lo que dicta el presente Laudo Arbitral de Derecho.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza
ARBITRO ÚNICO
SECRETARÍA ARBITRAL

367
trecentos
sesenta y siete

PARTE DEMANDANTE:

Razón Social : Consorcio Supervisor G y M
Representante : Fernando Jorge Morales Meza

PARTE DEMANDADA:

Razón Social : Municipalidad Distrital de Huácar
Representante : Cleber Mory Rojas

CONVENIO ARBITRAL:

"... CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.21 del artículo 45° de la Ley de Contrataciones del Estado..."

COMPETENCIA ARBITRAL

Conforme indica la Cláusula Décimo Octava del contrato y estando al acuerdo de las partes, se estableció la competencia del centro y su reglamento para conocer la presente causa, por lo que en aplicación del artículo 11° del D.L. 1071, atendiendo también al artículo 189.1 del RLCE y el Principio de autonomía de la voluntad o voluntariedad, las partes han tomado la decisión de sustraerse del sistema de justicia tradicional para someter la solución de sus conflictos a la justicia arbitral, con plena libertad para elegir a los árbitros, reglas del proceso, lugar y ley aplicable de ser el caso.

DESIGNACIÓN DEL ARBITRO ÚNICO:

La abogada Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza, ha sido nombrada como Árbitro Único, de acuerdo con el Reglamento del Centro y con la conformidad de las partes.

366
trescientos
sesenta y seis

TIPO DE ARBITRAJE:

El arbitraje es Institucional, Nacional y de Derecho conforme a lo dispuesto en la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO:

Producto del Contrato N° 28713-2022-BN de fecha 12 de julio del 2022, devenida de la Adjudicación Simplificada N° 0028-2021-BN, se dispuso la ejecución de la obra: "EJECUCIÓN DE OBRA; REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA AGENCIA 3 JUNÍN - JUNÍN".

3. PRINCIPALES ANTECEDENTES PROCESALES:

- 3.1. Que, con fecha 11 de setiembre de 2023 se realizó la Audiencia de Instalación de Tribunal Arbitral (en su calidad de Arbitro Único), en la cual se designó como árbitro único a la Abog. HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA con REG CAH N° 1853.
- 3.2. Que, con fecha 25 de setiembre de 2023 el demandante presenta su demanda arbitral y medios probatorios.
- 3.3. Que, con resolución arbitral N° 001-2023/HITS/AU/HCO de fecha 27 de setiembre de 2023, el tribunal declaro inadmisibile la demanda por la falta del pago del adelanto de gastos arbitrales de las partes.
- 3.4. Que, con Resolución Arbitral N° 02-2023/HITS/AU/ HCO de fecha 05 de octubre de 2023 se admitió a trámite la demanda y se corrió traslado al demandado.
- 3.5. Que, con Resolución arbitral N° 04-2023/HITS/AU/HCO de fecha 28 de octubre de 2023 se admite la contestación de la demanda y se corre traslado al consorcio.
- 3.6. Que, con fecha 21 de noviembre de 2023, se realizó el acta de Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios y se admiten las pruebas, otorgándose un plazo a las partes para que presenten sus alegatos finales.
- 3.7. Que, con fecha 30 de noviembre se realiza informe oral con la asistencia del demandante.
- 3.8. Que, con resolución arbitral N° 06-2023HITS/AU/HCO de fecha 14 de diciembre de 2023 se señala plazo para la emisión de laudo arbitral, la misma que se emitirá en el plazo de 15 días.

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
"CORPORACIÓN IMPERIUM"
SECRETARÍA ARBITRAL
Gloria Llanos Esquivel

HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA
ARBITRO ÚNICO

365
trececientos
sesenta y cinco

4. CONSIDERACIONES PRELIMINARES:

Del Marco Legal

En lo que concierne al marco normativo que se aplica a la relación contractual celebrada, es de mencionar que ésta se rige por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente a la fecha de convocatoria del proceso de selección. Consecuentemente, la ley aplicable al fondo de la controversia es la Ley N° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado" modificada por el Decreto Legislativo N° 1444 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF modificada con Decreto Supremo N° 162-2021-EF. De igual manera, también se aplicará la jurisprudencia en la materia emitida por la Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, así como el Código Civil, Reglamento del Centro y demás normas supletorias aplicables al caso, de acuerdo con las reglas establecidas en el Acta de Instalación de Fecha 11 de setiembre de 2023.

Respecto a la designación del Árbitro Único

La designación del Árbitro Único se efectuó de acuerdo con las reglas establecidas por las partes, no habiéndose planteado objeción o recusación alguna durante el proceso arbitral.

Del ejercicio legítimo del derecho de defensa de las partes

El demandante presentó su Demanda Arbitral dentro del plazo otorgado. La demandada fue debidamente emplazada con dicha demanda, la misma que fue contestada, no presentando reconvencción dentro del plazo.

Las partes, durante el proceso arbitral, ofrecieron medios probatorios que fueron incorporados por el Árbitro Único para tener mayores elementos para resolver.

Las partes tuvieron plena libertad para ofrecer y actuar todos los medios probatorios que consideraran pertinentes, sin limitación alguna, así como para expresar sus posiciones de hecho y de derecho, habiendo tenido amplia oportunidad de presentar sus alegatos escritos y de informar oralmente, con la participación de sus abogados, respetando en todo momento el Árbitro Único su irrestricto ejercicio del derecho de defensa en igualdad de condiciones en resguardo del debido proceso.

Del Laudo:

El presente laudo es emitido dentro del plazo establecido.

Se considera necesario resaltar que los medios probatorios deben tener por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, así como producir certeza en el juzgador respecto a las pretensiones planteadas, de acuerdo a lo consagrado por los principios generales en materia probatoria.

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Echevarría Tafur
SECRETARÍA ARBITRAL

Heidi Ivonne Torres Santos de Kuleza
ARBITRO ÚNICO

De igual forma, el Árbitro Único deja establecido que podrá analizar los puntos controvertidos en el orden que considere apropiado. De ser el caso, si decide pronunciarse sobre alguno de ellos, y si de ello resulta que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre uno o varios de los otros con los que guarde vinculación por la secuencia lógica de razonamiento, omitirá pronunciarse sobre estos últimos, expresando las razones de dicha omisión, sin que esto genere algún tipo de nulidad.

Asimismo, se advierte a las partes que la valoración de las pruebas en que se sustenta la decisión y los fundamentos de hecho y de derecho para admitir o rechazar las respectivas pretensiones y defensas de las partes, se van a desarrollar en forma conjunta en los considerandos del presente laudo.

Finalmente, el Árbitro Único señala que constituye un criterio unánimemente aceptado (extensible a los árbitros) que el juzgador no está obligado a exponer y refutar en sus sentencias todos y cada uno de los argumentos de las partes ni a reseñar el modo en que ha ponderado todas y cada una de las pruebas producidas. La eventual ausencia de mención en este Laudo de algún argumento, pieza o fundamento indicado por las partes no implica, empero, que se haya dejado de considerar todos los elementos de juicio relevantes que han sido aportados.

5. PUNTOS CONTROVERTIDOS:

Mediante Acta de Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios de fecha 21 de noviembre de 2023, se fijan los siguientes puntos controvertidos:

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde o no que el árbitro único declare nula y sin efecto legal la Resolución de Gerencia Municipal N° 054-2023-MDH/GM de fecha 09 de junio de 2023 y la Carta Notarial N° 001-2023-MDH/GM, emitidas por la demandada, por la que resuelven aplicar penalidades conforme al art. 190.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en la suma de S/ 552,000.00; (QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL Y 00/100) y determinar si corresponde o no que el árbitro único DECLARE ABSUELTO al contratista de la comisión de las penalidades indicadas en dicha resolución y en el Informe N° 109-2023-MDH/SGLSGYA/NJQ de fecha 09 de junio de 2023.

- ✓ **SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no que el árbitro único declare nula y sin efecto legal la Resolución de Gerencia Municipal N° 055-2023-MDH/GM de fecha 09 de junio de 2023 y la Carta Notarial N° 002-2023-MDH/GM, emitidas por la demandada, por la que decide resolver unilateralmente el Contrato N° 001-2022-MDH/A por supuesta acumulación de penalidad máxima del contratista y por haber reemplazado al

personal clave ofertado en contra de lo indicado por el art. 190.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- ✓ **TERCER PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no que el árbitro único declare consentida la RESOLUCIÓN DEL CONTRATO efectuado por el contratista mediante Carta Notarial N° 002-2023-CONSORCIO SUPERVISOR GyM/RLC, recepcionada por la entidad el 14 de junio de 2023, por la causal de incumplimiento de su obligación esencial de pagar la Valorización N° 04 correspondiente al mes de marzo 2023.
- ✓ **CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no que el árbitro único ordene a la demandada el pago a favor del demandante de la suma de S/ 323,824.48 (TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 48/100 SOLES), por concepto de reembolso y/o reintegro de valorizaciones adeudadas, indebidamente descontados por la entidad demandada.
- ✓ **QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no que el árbitro único ordene a la demandada Municipalidad Distrital de Huácar, la entrega a favor del demandante del Certificado de Conformidad por la Prestación del Servicio, conforme a la cláusula décima del Contrato N° 001-2022-MDH/A.
- ✓ **SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no que el árbitro único ordene a la demandada Municipalidad Distrital de Huácar la devolución y/o pago a favor del demandante de la suma de S/ 196,574.00 (CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES), entregados como Garantía de Fiel Cumplimiento según la Cláusula Séptima del Contrato de Supervisión de Obra N° 001-2022-MDH-A.
- ✓ **SÉPTIMO PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no que el árbitro único ordene a la demandada el pago a favor del demandante de una INDEMNIZACIÓN por los daños y perjuicios derivados de: i) Por la ilegal resolución del contrato sub materia realizada con Resolución de Gerencia Municipal N° 055-2023-MDH/GM; y ii) Por la ilegal ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento; indemnización que alcanza hasta por la suma de S/ 279,667.95 (Doscientos Setenta y Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Siete con 95/100 Soles), más intereses generados, conforme al numeral 36.2 del Artículo 36° de la Ley de Contrataciones del Estado, concordante con el numeral 166.2 del artículo 166° de su Reglamento.
- ✓ **OCTAVO PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar a cual de las partes procesales corresponde atribuir el pago de la totalidad de las costas y costos del proceso arbitral.

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM

SECRETARÍA ARBITRAL
Gabriela Lucero Echevarría Tzuc

ARBITRO ÚNICO
Heidi Ivonne Torres Santos de Kuleza

6. MEDIOS PROBATORIOS:

De conformidad con el numeral IV del Acta de Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios de fecha 21 de noviembre de 2023, se considerará los medios probatorios ofrecidos por las partes que han sido admitidos conforme al siguiente detalle:

Medios probatorios presentados por el DEMANDANTE

1. Contrato de Supervisión de Obra N° 001-2022-MDH-A.
2. Carta N° 003-2022-CONSORCIO GYM/RL, de fecha 23 de diciembre del 2022.
3. Resolución Gerencial Municipal N° 054-2023-MDH/GM, notificado el 13 de junio del 2,023.
4. Carta Notarial N° 001-2023-MDH/GM.
5. Resolución Gerencial Municipal N° 055-2023-MDH/GM, notificado el 13 de junio del 2,023.
6. Carta Notarial N°002-2023-MDH/GM, por la que se nos notifica las penalidades.
7. CARTA N°03-2023-CONSORCIO GyM/RL de Fecha 11 enero 2023.
8. CARTA N°04-2023-CONSORCIO GyM/RL de Fecha 11 enero 2023.
9. CARTA N°17-2023-CONSORCIO GyM/RL de Fecha 06 febrero 2023.
10. CARTA N°17-2023-CONSORCIO GyM/RL de Fecha 06 marzo 2023.
11. CARTA N°78-2023-CONSORCIO GyM/RL de Fecha 26 abril 2023.
12. CARTA N° 63-2023-CONSORCIO GyM/RL de Fecha 05 abril 2023.
13. CARTA N° 90-2023-CONSORCIO GyM/RL de Fecha 05 mayo 2023.
14. CARTA N° 122-2023-CONSORCIO GyM/RL: Fecha 05 junio 2023.
15. Carta Notarial N° 001-2023-CONSORCIO SUPERVISOR GyM/RLC.
16. Carta Notarial N° 002-2023-CONSORCIO SUPERVISOR GyM/RLC.
17. Carta N°133-2023-CONSORCIO.SUPERVISOR. GyM/RLC.
18. Carta N° 096-2023-CONSORCIO SUPERVISOR. GyM/RLC
19. Carta N° 034-2023-MDH/GM
20. Informe Pericial Contable N° 022-2023-REA de fecha 22 de setiembre de 2023.
21. Bases Integradas del Concurso Público N° 001-2021-MDH-CS

Medios probatorios presentados por el DEMANDADO

1. Acta de inicio de obra, de fecha 29 de diciembre de 2022
2. Acta de entrega de terreno de fecha 28 de diciembre de 2022
3. Carta N° 003-2022_ CONSORCIO GyM/RL de fecha 23 de diciembre de 2022
4. Cuaderno de registro con el Expediente 2151- (mesa de partes)
5. Informe N° 454-2022-MDH-SGLSGyA/JMML de fecha 27 de diciembre de 2022
6. Carta N° 096-2023-_ CONSORCIO SUPERVISOR GyM/RLC de fecha 11 de mayo de 2023

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
"CORPORACIÓN IMPERIUM"
Gabriela Lucero Echevarría Talur
SECRETARÍA ARBITRAL

7. Informe N° 347-2023-MDH-GIDUR-GST de fecha 10 de mayo de 2023
8. Carta N° 034-2023-MDH/GM de fecha 10 de mayo de 2023
9. Informe N° 517-2023-MDH-GIDUR-GST de fecha 08 de junio de 2023
10. Informe N° 109-2023-MDH-SGLSGYA/NJO de fecha 09 de junio de 2023
11. Informe N° 49-2023-MDH-OAJ/RRM de fecha 07 de junio de 2023
12. Resolución Gerencial Municipal N° 054-2023-MDH/GM de fecha 09 de junio de 2023
13. Informe N° 518-2023-MDH-GIDUR-GST de fecha 08 de junio de 2023
14. Resolución Gerencial N° 055-2023-MDH/GM de fecha 09 de junio de 2023
15. Memorándum N° 301-2023-MDH/GM, de fecha 16 de agosto de 2023
16. Acta de transferencia de documentos de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, de fecha 12 de diciembre de 2022.

Medios probatorios de OFICIO

1. Casación N° 2084-2015/LIMA
2. Casación N° 3470-2015/LIMA NORTE

7. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO QUE EL ÁRBITRO ÚNICO DECLARE NULA Y SIN EFECTO LEGAL LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 054-2023-MDH/GM DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023 Y LA CARTA NOTARIAL N° 001-2023-MDH/GM, EMITIDAS POR LA DEMANDADA, POR LA QUE RESUELVEN APLICAR PENALIDADES CONFORME AL ART. 190.2 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO EN LA SUMA DE S/ 552,000.00; (QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL Y 00/100) Y DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO QUE EL ÁRBITRO ÚNICO DECLARE ABSUELTO AL CONTRATISTA DE LA COMISIÓN DE LAS PENALIDADES INDICADAS EN DICHA RESOLUCIÓN Y EN EL INFORME N° 109-2023-MDH/SGLSGYA/NJQ DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023.

Resumen de la posición del DEMANDANTE

- 7.1. La demandante señala que mediante Resolución Gerencial Municipal N° 054-2023-MDH/GM, la entidad le aplica "otras penalidades", por haber solicitado el cambio de los profesionales clave (jefe de Supervisión, Especialista en Estructuras, Especialista en Instalaciones Electromecánicas y Especialista de SSOMA) dentro de los 60 días posteriores al inicio de su participación, sin embargo, la misma devendría en ilegal pues se habría incurrido en los siguientes vicios:

- La penalidad aplicada vulnera el criterio de proporcionalidad establecido por el artículo 163.1 del RLCE.
- La penalidad aplicada vulnera e inobserva el procedimiento para la aplicación de "otras penalidades".
- La penalidad inobserva la finalidad de la aplicación de penalidades
- La penalidad inobserva o incumple los supuestos para su aplicación, indicados en el art. 163.1 del RLCE, por ende, se trata de una conducta atípica y no sancionable.

- 7.2. La demandante señala que no incurrió en la conducta sancionada pues el cambio del personal clave se dio posterior a los 60 días siguientes al inicio de su participación, pues si bien el contrato se firmó el 02 de febrero de 2022, sin embargo, recién con fecha 29 de diciembre de 2022 (casi 11 meses después) se dio inicio efectivo al proyecto, ello por causas atribuibles únicamente a la entidad.
- 7.3. Señala también que resulta desproporcional e irrazonable creer que luego de la firma del contrato el personal clave acreditado se mantendrá expectante y esperando indefinidamente el inicio de sus labores efectivas descritas en el contrato, y se podría ver distorsionado el tiempo mínimo de permanencia del personal clave.

Resumen de la posición de la DEMANDADA

- 7.4. La demandada señala que mediante Informe N° 454-2022-MDH-SGLSGyA/JMML, emitido por la Sub Gerencia de Logística, Servicios Generales y Almacén de la entidad, se declaró procedente el cambio del personal clave, sin el debido sustento técnico y legal, ya que el informe de la oficina de Logística carece de sustento técnico y no habría respetado la legalidad de aplicar el cumplimiento del numeral 190.2 del artículo 190 del RLCE.

Señala también que se ve claramente el incumplimiento del contrato por la parte demandante, ya que solicito el cambio de personal clave sin el debido sustento técnico e inclusive antes del inicio de la obra ya que, si bien habrían transcurrido 320 días calendario y no habiéndose iniciado la obra, no es causa justa para solicitar el cambio de personal clave ya que no estaría respetando el contrato suscrito en su momento.

Posición definitiva del ARBITRO ÚNICO

- 7.6. En el marco de una contratación pública, las actuaciones que efectúe el Estado son considerados como actos administrativos y por ende, sujetos y regulados por la LPAG y la Ley, lo cual no implica un desconocimiento del orden de prelación previsto en el numeral 45.10 del artículo 45° de la Ley de Contrataciones del Estado, debiendo cumplir los requisitos exigidos en los citados dispositivos, siendo así, se procederá con el análisis

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
SECRETARÍA ARBITRAL
Gabriela Lucero Echevarría Teller

Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza
ARBITRO ÚNICO

359
trescientos
Cincuenta y nueve

del caso exigiendo el cumplimiento de los requisitos de debida motivación y competencia, previstos en el artículo 3° de la LPAG.

- 7.7. Teniendo en cuenta la naturaleza de la pretensión, podemos advertir que la misma está referida a las penalidades cuya definición la encontramos en nuestra legislación civil, concretamente el artículo 1341° del Código Civil nos dice que es el pacto por el que se acuerda que, en caso de incumplimiento, uno de los contratantes queda obligado al pago de una penalidad, la cual tiene el efecto de limitar el resarcimiento a esta prestación y a que se devuelva la contraprestación, si la hubiere, salvo que se haya estipulado la indemnización del daño ulterior.

- 7.8. Por su parte, el RLCE contempla 02 tipos de penalidades: la penalidad por mora y otras penalidades; la primera se impone ante el incumplimiento injustificado de los plazos contractuales, mientras que las segundas son conductas sancionadas distintas a la penalidad por mora, cuya finalidad es desincentivar el incumplimiento del contratista y resarcir posibles perjuicios que se pudiera causar a la entidad; para tal fin a continuación citaremos los artículos 161°, 162° y 163° del RLCE que dicen:

“... Artículo 161. Penalidades

161.1. El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la información brindada por el área usuaria, las mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria.

161.2. La Entidad prevé en los documentos del procedimiento de selección la aplicación de la penalidad por mora; asimismo, puede prever otras penalidades. Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

161.3. En el caso de obras, dentro de las otras penalidades que se establezcan en los documentos del procedimiento, incluyen las previstas en el capítulo VI del presente título.

161.4. Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Artículo 162. Penalidad por mora en la ejecución de la prestación

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Echevarría Tatur
SECRETARIA ARBITRAL

ARBITRO ÚNICO

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Echevarría Tahir
SECRETARÍA ARBITRAL

162.1. En caso de **retraso injustificado** del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: (...)

162.2. Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica o entregas parciales, a la prestación individual que fuera materia de retraso.

162.3. En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestación materia de retraso, la Entidad puede establecer en los documentos del procedimiento de selección la penalidad a aplicarse.

162.4. Para los supuestos que por la naturaleza de la contratación, la fórmula indicada en el presente artículo no cumpla con su finalidad, el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Resolución Ministerial puede establecer fórmulas especiales para el cálculo de la penalidad por mora.

162.5. **El retraso se justifica** a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese último caso, la calificación del retraso como justificado por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo.

Artículo 163. Otras penalidades

163.1. Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer penalidades distintas a la mencionada en el artículo 162, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, incluyen los supuestos de aplicación de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

163.2. Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora... " (Énfasis agregado)

- 7.9. Conforme a ello, la norma ha previsto que el contrato incluya la aplicación de penalidades ante el incumplimiento de las obligaciones del contratista, siempre y cuando sean

objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria; la Opinión N° 023-2017/DTN nos da mayor alcance respecto a tales criterios y nos indica que:

- i) La objetividad implicaba que la Entidad establezca de manera clara y precisa los tipos de incumplimiento que serían penalizados, los montos o porcentajes de la penalidad para cada tipo de incumplimiento, y la forma o procedimiento mediante el que se verificaría la ocurrencia de tales incumplimientos, según la naturaleza y características particulares de cada contratación;
- ii) Por su parte, la razonabilidad implicaba que cada uno de los montos o porcentajes de la penalidad que se aplicarían al contratista sean proporcionales a la gravedad y reiteración del incumplimiento, y;
- iii) La congruencia con el objeto de la convocatoria implicaba que se penalizara el incumplimiento de alguna obligación comprendida o relacionada con el objeto de la convocatoria.

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gisela Enciso Solivera
SECRETARÍA ARBITRAL

7.10. Ahora, la presente controversia está referida a la aplicación de "otras penalidades", bajo su subtipo de incumplimiento de permanencia del personal clave, previsto y sancionado en el numeral 190.2 del artículo 190 del RLCE que dice:

"... 190.2. El personal acreditado permanece como mínimo sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o por el íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a sesenta (60) días. El incumplimiento de esta disposición acarrea la aplicación de una penalidad no menor a la mitad (0.5) ni mayor a una (1) UIT por cada día de ausencia del personal en la obra. La aplicación de esta penalidad solo puede exceptuarse en los siguientes casos: i) muerte, ii) invalidez sobreviniente e iii) inhabilitación para ejercer la profesión, eventos que el contratista informa por escrito a la Entidad como máximo al día siguiente de conocido el hecho, a efectos de solicitar posteriormente la autorización de sustitución del personal..."

7.11. Entonces, la controversia está referida a la aplicación de "otras penalidades" distintas a la penalidad por mora, materializadas a través de la Resolución de Gerencia Municipal N° 054-2023-MDH/GM de fecha 09 de junio de 2023 y la Carta Notarial N° 001-2023-MDH/GM, razón por la que el tribunal procede a verificar si la misma ha sido aplicada observando los requisitos señalados por el artículo 163° del RLCE, esto es:

- a) Que se haya cumplido con incluir los supuestos de aplicación de la penalidad
- b) La forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto
- c) El procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULEZA
ARBITRO ÚNICO

356
Trescientos
Cincuenta y seis

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Echevarría Tola
SECRETARÍA ARBITRAL

7.12. **Respecto a los supuestos de aplicación de la penalidad:** es pertinente indicar que según el Anexo Único – Anexo Definiciones, el contrato es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica dentro de los alcances de la Ley y de dicho Reglamento; además, según el artículo 116 de dicho cuerpo normativo, el contrato está conformado por el documento que lo contiene, los documentos del procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas y la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes; de igual forma, dentro del ordenamiento en materia de contrataciones es comúnmente aceptado el hecho que los supuestos a penalizar deben de estar correctamente definidos en el contrato, ya que hacer lo contrario sería inobservar el criterio de objetividad establecido por la propia norma.

7.13. Para nuestro caso, la Resolución de Gerencia Municipal N° 054-2023-MDH/GM imputa la comisión de la conducta indicada en el numeral 190.2 del artículo 190 del RLCE, incumplimiento de permanencia del personal clave durante los sesenta días posteriores al inicio de su participación; ahora, la conducta concreta sancionada se encuentra descrita por la cláusula décimo tercera del contrato, que señala:

N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en el plazo previsto.	Según informe de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural

7.14. Como podrá observarse, es el contrato en sí mismo, a través de su cláusula décimo tercera, quien delimita y enumera los supuestos a penalizar, no advirtiéndose contradicción o vicios sobre su contenido textual ni sobre los supuestos invocados por la Resolución de Gerencia Municipal N° 054-2023-MDH/GM, pues resultan claras las conductas a ser sancionadas, concluyéndose que las penalidades aplicadas si cumplen con este presupuesto.

7.15. **Respecto a la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto:** Sobre este presupuesto, deberemos remitirnos nuevamente al numeral 1 de la cláusula décimo tercera del Contrato, por cuanto en ellas se especifica la forma de cálculo de cada supuesto penalizable, así tenemos que:

N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en el plazo previsto.	Según informe de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural

CEN
O DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gustavo Lucero Echevarría Alfaro
SECRETARÍA ARBITRAL

7.16. Como podrá observarse, es el contrato en sí mismo quien especifica claramente la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto, sin embargo, también es cierto que la norma a través del numeral 161.2 del artículo 161° del RLCE y la propia cláusula décimo tercera del Contrato, han establecido que **cada tipo de penalidad no debe exceder el 10% del monto del contrato vigente (tope máximo)**; para el presente caso, la demandada mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 054-2023-MDH/GM ha aplicado una penalidad por S/ 552,000.00, y si tenemos en cuenta que el monto del contrato es por S/ 1,994,740.00, entonces, la penalidad máxima no debería exceder la suma de S/ 199,474.00 (Ciento Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro con 00/100 Soles), de lo cual se advierte que la penalidad aplicada supera ampliamente el tope máximo establecido, por ende transgrediendo el marco legal y el acuerdo establecido entre las partes plasmado en el contrato, desprendiéndose que **dicha penalidad no cumple con este presupuesto.**

7.17. Respecto al procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar: el numeral 1 de la cláusula décimo tercera del Contrato señala:

N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en el plazo previsto.	Según informe de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural

7.18. Observamos que el contrato ha establecido como único procedimiento que previamente se debe contar con el informe de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural de la entidad, mediante la cual se verifique la aplicabilidad de la penalidad así como los requisitos para su procedencia, por lo que su incumplimiento acarrearía la improcedencia de la sanción económica, además, ello guarda relación con el Principio del Debido Procedimiento¹, también invocable en esta instancia, destinado a resguardar las garantías mínimas de los derechos de las partes, tal como el derecho a la defensa y el derecho a obtener una decisión motivada, fundada en derecho y a las pruebas aportadas; para el presente caso podemos observar que el acto administrativo mediante el cual la entidad ejerce su atribución de aplicar "otras penalidades" es la Resolución de Gerencia Municipal N° 054-2023-MDH/GM, materializada a su vez frente al contratista mediante la Carta Notarial N° 001-2023-MDH/GM; ahora, de la revisión de la resolución en cuestión,

¹ LCE. Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones.

Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios, sin perjuicio de la aplicación de otros principios generales del derecho público. Estos principios sirven de criterio interpretativo e integrados para la aplicación de la presente ley y su reglamento, y como parámetros para la actuación de quienes intervengan en dichas contrataciones...

podemos advertir que de manera expresa se indica que el sustento o fundamento para su decisión de aplicar la penalidad es el Informe N° 109-2023-MDH/SGLSGyA/NJQ de fecha 09 de junio de 2023, emitido por la oficina de Subgerencia de Logística, Servicios Generales y Almacén:

Que, mediante Informe N.º 109-2023-MDH/SGLSGyA/NJQ, de fecha 09 de junio de 2023, emitido por la Subgerencia de Logística Servicios Generales y Almacén, de asunto Aplicación de Penalidades por Incumplimiento de Contrato; la Subgerencia de Logística servicios Generales y Almacén, concluye que en estricta relación con el objetivo de satisfacer la necesidad de contar con el servicio de consultoría del objeto de la contratación y visto los actuados por parte del Área usuaria, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural y la Opinión Legal de la Oficina de Asesoría Jurídica, se comunica la decisión de aplicar la Penalidad al Contrato de Supervisión de Obra N.º 001-2022-MDH//A, Servicio de supervisión de Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD HUACAR DE LA MICRO RED HUACAR, DISTRITO DE HUACAR – AMBO – HUÁNUCO", por un monto que asciende a la suma de S/552,000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CON 00/100 SOLES).

- 7.19. Así también, el propio Informe N° 109-2023-MDH/SGLSGyA/NJQ hace un análisis detallado del hecho penalizado, realiza el calculo del monto correspondiente y de manera expresa aplica la penalidad contra el contratista:

Contratista	CONSORCIO SUPERVISION GyM
Contrato	CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 001-2022-MDH-A
Normatividad Aplicada	Art. 190.2 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 30225
Monto Contractual	S/ 1'994,740.00
Supuesto de Otras Penalidades	Supuesto N° 01, 0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en el plazo previsto
Cantidad de Personal	04 Personal Clave [01 jefe de Supervisión (01 permanencia) y 03 Especialistas (01 Permanencia)]
Cantidad de días a penalizar	60 días calendario (DC)
Valor 01 UIT (2022)	S/ 4,600.00
Cálculo Otras Penalidades	1 Personal * 0.5 UIT * 1 permanencia * 60 DC + 3 Personales x 0.5 UIT * 1 permanencia * 60 DC = Total Penalidad 1 x 2300 x 1 x 60 + 3 x 2300 x 1 x 60 = Total Penalidad 138,000 + 414,000 = 552,000
Total Penalidad	S/ 552,000.00

Adicionalmente, cabe precisar que la finalidad de establecer dichas penalidades es desincentivar el incumplimiento del EL CONTRATISTA, así como resarcir a la Entidad por el perjuicio que le hubiera causado tal incumplimiento o retraso en la ejecución de las prestaciones a su cargo.

CONCLUSIONES

En tanto mediante el presente, en cumplimiento de las funciones encomendadas esta Sub Gerencia de Logística, Servicios Generales y Almacén; en estricta relación con el objetivo de satisfacer la necesidad de contar con el servicio de consultoría del objeto de la contratación y visto los actuados por parte del área usuaria la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural y la Opinión Legal de la Oficina de Asesoría Jurídica de esta entidad, se comunica la decisión de Aplicar la Penalidad al Contrato de Supervisión de Obra N° 001-2022-MDH-A, SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD HUÁCAR DE LA MICRO RED HUÁCAR, DISTRITO DE HUÁCAR-AMBO-HUÁNUCO". Por monto que asciende la Suma de S/ 552,000.00 (Quinientos cincuenta y dos mil con 00/100 Soles).

Se recomienda tomar acciones a fin de resolver el Contrato ya que el monto sobrepasaría el 10% del Monto Contractual que equivale a S/. 199,774.00 (Ciento Noventa y Nueve Mil Setecientos Setenta y Cuatro con 00/100 Soles), por ende, la Entidad debería Resolver el Contrato en amparo del reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, en vista de la falta grave que la Supervisión hizo cometer a los funcionarios.

- 7.20. Ahora bien, respecto al Informe N° 517-2023-MDH/GIDUR/GST de fecha 08 de junio de 2023 emitido por la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, invocado por la demandada como posible "sustento" de la penalidad aplicada, de la revisión de dicho

documento y del propio argumento de la demandada, se tiene que el precitado informe únicamente sirvió para solicitar la opinión legal respecto al incumplimiento del contrato, tal como se muestra a continuación:

que menciona que la Subgerencia de logística habría aplicado las penalidades a través del Informe N° 109-2023-MDH-SGLSGyA/NJQ, a ello señora Arbitro aunque no esté de forma expresa en la Resolución Gerencia N° 054-2023-MDH/GM, pero con fecha 08 de junio del 2023, la Gerencia de Infraestructura y desarrollo urbano y rural emite el informe N° 517-2023-MDH-GIDUR-GST, donde **solicita opinión legal** para aplicación de penalidades respectivas y posteriormente con fecha 09 de junio del 2023 la Subgerencia de Logística recién emite informe técnico sobre la aplicación de penalidades solicitadas por el área usuaria.

Tanto mas si tenemos cuenta que del contenido de la Resolución de Gerencia Municipal N° 054-2023-MDH/GM, en ninguna parte del acto administrativo se menciona, toma como referencia o se remite al Informe N° 517-2023-MDH/GIDUR/GST como sustento técnico para la aplicación de la penalidad pues, contrariamente, dicho acto administrativo se remite expresamente al Informe N° 109-2023-MDH/SGLSGyA/NJQ, concluyéndose que esta última es el procedimiento por el cual se aplica la penalidad sub examine, lo que a su vez configura claramente el incumplimiento del procedimiento establecido por el contrato, desprendiéndose que **dicha penalidad no cumple con este presupuesto** para su procedencia.

7.21. Conforme a lo expuesto podemos concluir que si bien la norma le ha otorgado a la entidad la atribución de aplicar sanciones económicas sobre el contratista ante el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, también es cierto que dicha atribución debe ser ejercida respetando los criterios de objetividad, razonabilidad y congruencia establecidos por los artículos 161°, 162° y 163° del RLCE, situación que la demandada ha incumplido al momento de aplicar penalidades mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 054-2023-MDH/GM, por lo que la misma deviene en nula, correspondido consecuentemente que se absuelva al contratista de la comisión de las penalidades indicadas.

7.22. Por otro lado, la suscrita considera pertinente pronunciarse respecto a los argumentos de la demandada en el sentido de atribuir las deficiencias y/o vicios en la aplicación de la penalidad, hacia las anteriores gestiones y funcionarios de dicha comuna, señalando, entre otros, que:

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM

Gabriela Lucero Echegaray Taur

SECRETARÍA ARBITRAL

2.9. Ahora, sobre el cambio de personal clave solicitado por el representante común del Consorcio Supervisor GyM, parte con la carta N° 003-2022-CONSORCIO GyM/RL, de fecha 23 de diciembre del 2022, donde dicho expediente es derivado a la Subgerencia de Logística, servicios generales y almacén, donde mediante informe N° 454-2022-MDH-SGLSGyA/JMML, declara PROCEDENTE el cambio de personal clave sin el debido sustento técnico y legal, ya el numeral 190.2 del Artículo 190 del RLCE,

este tema a pesar que nunca fue notificado al Consorcio Supervisor, las malas intenciones de aceptar el cambio de personal clave, ya que el informe de logística carece de sustento técnico y no habría respetado la legalidad de aplicar el cumplimiento del artículo ya mencionado, simplemente argumento: "Del párrafo anterior, y luego de la revisión de la información presentada por el representante común del CONSORCIO SUPERVISOR GYM; se ha

2.10. Es más, dicho informe técnico de la Subgerencia de Logística, servicios generales y almacén fue remitido a la Gerencia Municipal el día 27 de diciembre del 2022 a horas 08:50 A.M, donde se puede apreciar en el cuaderno de registro que el Gerente Municipal no habría dado respuesta declarando procedente al Consorcio Supervisor sobre su petición; desde ahí se puede observar señora Arbitro que las intenciones de realizar el cambio de personal clave sin el sustento técnico y legal se daban de las áreas comprometidas en emitir sus debidos informes, ya que dicha solicitud nunca fue analizado por la oficina de Infraestructura y asesoría legal; pues permitiendo la Gerencia Municipal caer en error y que nunca fue respondido la solicitud y consecuentemente el Consorcio Supervisor quisiera obtener derechos ganados a través del numeral 190.5 del Art 190 del RLCE.

2.17. Para dejar en claro sobre la aplicación de penalidades y haber alcanzado el monto máximo para proceder con la resolución de contrato se procedió de acuerdo a norma por incumplimiento de obligaciones por parte del contratista, a pesar de que ellos se amparan en el numeral 190.5 del RLCE, mi representada no podrá ser parte de la vulneración del principio de legalidad y el debido procedimiento y es más habiendo evidencias del forzado procedimiento que se dio para la aceptación del cambio de personal clave, teniendo en cuenta señora Arbitro que todo inicio de trámite se dio a puertas de cerrar la gestión 2019-2022, y es más teniendo en cuenta los días feriados y no laborales que se dieron por norma en días de navidad y año nuevo, dejando en constancia también que la Gerencia de Infraestructura, desarrollo urbano y rural no recibió el cargo

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Luccio Echegaray Taur
SECRETARIA ARBITRAL

2.21. Por otro lado, señora Arbitro la parte demandante señala que mi representada se contradice toda vez que aplicó las penalidades después de varios meses de acaecidos las infracciones pero sin embargo se han aprobado las valorizaciones presentadas hasta la fecha diversas cartas; a ello, debemos de dejar en claro una vez más que el cambio de personal clave ha sido de manera premeditada, ya que parte del informe de logística N° 454-2022-MDH-SGLSGyA/JMML, que aprobaron sin el debido procedimiento establecido en el RLCE y que indujeron a error a que este no sea respondido dentro del plazo establecido en el numeral 190.5 del RLCE; y es más, es evidente las malas intenciones de iniciar una obra al finalizar el año y en cierre de gestión, cuando eso días son entrega de cargo y más aún el día viernes 30 de diciembre del 2022 ha sido considerado día no laborable conforme al D.S N° 033-2022-PCM, con respecto al mismo punto como nueva gestión no se tuvo la documentación completa y no se pudo corroborar la existencia del personal clave ofertado al momento de perfeccionar el contrato; por ende, se tuvo en cuenta las diversas cartas presentadas pero teniendo en cuenta que toda las cartas han sido remitidos por el representante legal común, pero no directamente por el Jefe de Supervisión.

7.23. Tales argumentos de ninguna manera configuran o demuestran los hechos que se pretenden imputar, ya que se tratan de meras especulaciones no corroboradas con documento o medio probatorio alguno, pues incluso dichos actos administrativos cuestionados actualmente se mantienen vigentes; además, el hecho del cambio de gestión edil y subsiguiente entrega de cargo, no es causa que justifique el incumplimiento u observancia de las formalidades para que la entidad ejerza sus atribuciones dentro del contrato, ya que al tener la municipalidad personería jurídica de derecho público, **todas sus actuaciones, funciones, actos u omisiones, dentro del marco de su competencia, se entienden por realizadas independientemente de los funcionarios que estén a cargo de su dirección o que tengan delegaciones específicas para ello**; en otras palabras, la entidad pública responde por sus propios actos como una persona jurídica, independientemente de los funcionarios a cargo, sobre quienes podría existir responsabilidad funcional; tal como menciona el literal VI de la Directiva N° 002-2010-PCM/SGP "Disposiciones Relacionadas a la Definición del concepto de Entidad Pública y la validación del Registro Preliminar de las Entidades Públicas del Estado Peruano" aprobado con Resolución Ministerial N° 374-2010-PCM que dice:

"... Se considera Entidad Pública a toda organización del Estado Peruano, con Personería jurídica de Derecho Público, creada por norma expresa en el que se le confiere mandato a través del cual ejerce funciones dentro del marco de sus competencias y atribuciones, mediante la administración de recursos públicos,

para contribuir a la satisfacción de las necesidades y expectativas de la sociedad, y como tal está sujeta al control, fiscalización y rendición de cuentas..."

- 7.24. Considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde declarar **FUNDADA** en todos sus extremos el presente punto controvertido.

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO QUE EL ÁRBITRO ÚNICO DECLARE NULA Y SIN EFECTO LEGAL LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 055-2023-MDH/GM DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023 Y LA CARTA NOTARIAL N° 002-2023-MDH/GM, EMITIDAS POR LA DEMANDADA, POR LA QUE DECIDE RESOLVER UNILATERALMENTE EL CONTRATO N° 001-2022-MDH/A POR SUPUESTA ACUMULACIÓN DE PENALIDAD MÁXIMA DEL CONTRATISTA Y POR HABER REEMPLAZADO AL PERSONAL CLAVE OFERTADO EN CONTRA DE LO INDICADO POR EL ART. 190.2 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

Resumen de la posición del DEMANDANTE

- 7.25. La demandante señala, respecto a la causal de resolución del contrato, que la demandada ha basado su decisión en la acumulación máxima de penalidades indicada en el inciso b) del art. 164.1 del RLCE; sin embargo ello es erróneo ya que quedó demostrado que la aplicación de penalidades mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 054-2023-MDH/GM y Carta Notarial N° 001-2023-MDH/GM, son actos nulos e ineficaces por cuanto dichos actos adolecen de los requisitos de validez del acto administrativo, tales como:

- La penalidad aplicada vulnera el criterio de proporcionalidad establecido por el artículo 163.1 del RLCE.
- La penalidad aplicada vulnera e inobserva el procedimiento para la aplicación de "otras penalidades".
- La penalidad inobserva la finalidad de la aplicación de penalidades
- La penalidad inobserva o incumple los supuestos para su aplicación, indicados en el art. 163.1 del RLCE, por ende, se trata de una conducta atípica y no sancionable.
- El cambio del personal clave se dio posterior a los 60 días siguientes al inicio de su participación, por lo que no es procedente la aplicación de penalidad.

Resumen de la posición de la DEMANDADA

- 7.26. La demandada señala que resolvió el contrato por la causal indicada en el literal b) del numeral 164.1 del artículo 164 del RLCE, ya que ésta se configura cuando se "acumula" el monto máximo de penalidad, toda vez que el contratista habría cambiado al personal

clave infringiendo el artículo 190 del RLCE, situación que lo habilita a resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista.

Posición definitiva del ARBITRO ÚNICO

- 7.27. Tal como señalan MORÓN URBINA y AGUILERA B.², la resolución del contrato es una forma de terminación anticipada del contrato, y se produce cuanto una de las partes falta al cumplimiento de sus prestaciones, pese haber sido requerido previamente para que subsane su incumplimiento, o se torna imposible, de manera definitiva, su continuación por caso fortuito o fuerza mayor.
- 7.28. Siguiendo la posición de MORÓN URBINA y AGUILERA B.³ respecto a la resolución del contrato por parte de la entidad contratante, ésta puede dar por concluido el contrato por culpa del contratista si este incurre en incumplimiento de obligaciones contractuales o legales -engaño en el material empleado, falsas mediciones de avances, negligencia en el cumplimiento del servicio, no alcanzar los rendimientos o índices de servicios, no iniciar prestaciones, ceder contrato, subcontratar sin autorización- o si paraliza o reduce injustificadamente la ejecución de la prestación, mediante el abandono o interrupción de trabajos o si acumula el máximo de penalidad por mora.
- 7.29. En el marco de las pretensiones materia de análisis, la suscrita advierte que es relevante determinar, a efectos de llegar a una conclusión concreta respecto a cada una de las materias sometidas a análisis, si es que se cumplieron las condiciones necesarias para que la resolución contractual sea válida. En este análisis, esta Ábitro Único evaluará las posiciones vertidas por ambas partes, por un lado, la del Consorcio que señala que cumplió con sus obligaciones contractuales, correspondiendo que su contraparte ejecute la contraprestación respectiva; y el de la Entidad, que considera que su contraparte no ha cumplido con la correcta ejecución de sus obligaciones. En la medida que lo pretendido por el Consorcio es que se declare sin efecto la resolución contractual efectuada por la Entidad a través de la Resolución de Gerencia Municipal N° 055-2023-MDH/GM de fecha 09 de junio de 2023 y Carta Notarial N° 002-2023-MDH/GM, esta última como medio para dar a conocer al contratista la resolución del contrato; por otro lado, es la posición de la Entidad, se declare la validez de la resolución del contrato ante el incumplimiento de obligaciones por parte del Demandante. De manera que, esta Ábitro Único considera necesario, preliminarmente, verificar si, efectivamente, la resolución contractual planteada por la Entidad ha cumplido con la formalidad que exige la normativa del caso.

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Pacheco
SECRETARÍA ARBITRAL

Heidi Ivonne Torres Santos de Kuleza
ARBITRO ÚNICO

² MORÓN URBINA, Juan Carlos y AGUILERA B., Zita. Aspectos Jurídicos de la Contratación Estatal- Colección Lo Esencial del Derecho N° 9. Fondo Editorial de la PUCP, 1° Edición. Lima-Perú. 2017. Pág. 160.

³ Ob. Cit. Pág. 161

- 7.30. Es así que, con fecha 17 de julio de 2023, la demandante ha ejercido su derecho de resolver el contrato mediante Carta Notarial N° 002-2023-MDH/GM y Resolución de Gerencia Municipal N° 055-2023-MDH/GM:

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Pacheco
SECRETARÍA ARBITRAL

REGIÓN HUÁNUCO - PROVINCIA AMBO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
HUÁCAR
"Tierra de embudo y tradición"

GERENCIA MUNICIPAL

CARTA NOTARIAL N° 002-2023-MDH/GM

SEÑOR : CONSORCIO SUPERVISION GyM
BQ. Huayopampa N° 1-26 Tercer Piso
Urbanización Huayopampa Huánuco.
Jirón Abtao N° 1868 Huánuco

ASUNTO : NOTIFICO RESOLUCIÓN

De mi mayor consideración:

Por el presente documento que se le hará llegar por conducto notarial en la fecha, la Resolución Gerencia Municipal N° 55-2023-MDH/GM de 09 de junio de 2023; que resuelve el contrato N° 001-202-MDH/A de fecha 02 del 2022 de supervisión de Obra del proyecto "MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD DE LA MICRO RED HUÁCAR, DISTRITO DE HUÁCAR – AMBO – HUÁNUCO", por las causales del incumplimiento del contratista, habiéndose reemplazado al personal ofertado soslayando el plazo establecido por ley.

Sin otro particular quedo de usted.

NOTARIA "MOFALES CASELO"
RECEPCIÓN
13 JUN 2023
N° 730-23
S. S. HUÁNUCO, HUÁNUCO PERÚ

13 Hojas
DOCUMENTO
PARA SER CURSADA
POR ESTA NOTARÍA

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- RESOLVER, el Contrato N.º 001-2022-MDH/A, de fecha 02 de febrero de 2022 de Supervisión de Obra del proyecto "MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD DE LA MICRO RED HUACAR, DISTRITO DE HUACAR – AMBO – HUANUCO" por las causales de incumplimiento del contratista, habiéndose reemplazado al personal ofertado soslayando el plazo establecido por ley, siendo que el personal propuesto no ha merecido el debido análisis del cumplimiento del perfil y las características técnico-profesionales que se exigieron en las bases, según lo previsto en el numeral 36.1 del artículo 36º de la Ley de Contrataciones del Estado y en el numeral 164.1 del artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- 7.31. Como se podrá observar, la demandada ha ejercido su derecho de resolver el contrato invocando para ello la causal señalada en el inciso b) numeral 164.1 del artículo 164º del RLCE y siguiendo el procedimiento establecido por el numeral 165.4 del Artículo 165º del RLCE, es decir, ha resuelto el contrato de forma inmediata y sin el requerimiento previo que señalan los numerales 165.1 y 165.2 del mismo cuerpo normativo:

397
Derechos
Cuarenta y siete

"... 164.1. La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos en que el contratista: (...) b) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo (...)

165.4. La Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato..."
(Énfasis agregado)

Conforme a ello, si bien la norma establece como condición previa para la resolución contractual, que la parte que se considere agraviada requiera a su contraparte el cumplimiento de sus obligaciones, no obstante, la propia norma ha establecido excepciones y ha facultado únicamente a la Entidad la resolución inmediata del contrato y sin apercibimiento previo para determinados casos; entonces, a la luz de la causal invocada para la resolución del contrato y de la documentación sustentatoria aparejada en autos, se tiene que la Entidad si cumplió con el procedimiento establecido.

7.32. Habiéndose revisado el cumplimiento formal del procedimiento de resolución contractual por parte de la Entidad, esta Árbitro Único estima necesario pasar a revisar los hechos ocurridos con posterioridad a la suscripción del contrato, a fin de realizar un análisis en conjunto que pueda determinar si la resolución contractual se encontraba o no debidamente justificada.

7.33. Para tal efecto, corresponde verificar si es que la decisión de resolver el contrato encuentra su sustento, por lo que, revisadas las razones por las cuales la Entidad comunicó al Consorcio la resolución contractual, se evidencia que la misma se sustentó en un hecho concreto: **la acumulación del tope máximo de penalidades**; por lo que, corresponde verificar, si el Consorcio habría incurrido o no en los incumplimientos descritos por la Entidad que sustentarían la resolución contractual efectuada.

7.34. Conforme a ello, tratándose de la aplicación de penalidad por la causal de incumplimiento de permanencia del personal clave, previsto y sancionado en el numeral 190.2 del artículo 190 del RLCE, entonces, la misma se configura como "otras penalidades" distintas a la penalidad por mora, razón por la que se debe de verificar si la misma ha sido aplicada observando los requisitos señalados por el artículo 163° del RLCE, esto es:

- d) Que se haya cumplido con incluir los supuestos de aplicación de la penalidad
- e) La forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Eschaurria Tafiur
SECRETARÍA ARBITRAL

Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza
ARBITRO ÚNICO

f) El procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

- 7.35. Ahora, remitiéndonos a los fundamentos indicados en los numerales 7.12 al 7.21 del presente laudo, corroborado con los medios probatorios que lo sustentan, este tribunal arbitral ha determinado que la aplicación de penalidad por la causal de incumplimiento de permanencia del personal clave, no satisface los requisitos de la forma de calculo y el procedimiento de verificación de la penalidad, ya que, como se detalló en los numerales citados, la penalidad supera ampliamente el tope máximo establecido por el numeral 161.2 del artículo 161° del RLCE y la cláusula décimo tercera del Contrato, y también se ha incumplido el procedimiento establecido por el contrato, por lo que se determino que la penalidad aplicada deviene en nula.
- 7.36. Conforme a ello, se puede concluir que la causal invocada para la resolución inmediata del contrato es inexistente, lo que a su vez implica que la Carta Notarial N° 002-2023-MDH/GM y Resolución de Gerencia Municipal N° 055-2023-MDH/GM adolecen de vicios sancionados con la nulidad, ya que han sido emitidas transgrediendo el marco legal vigente y las reglas contractuales establecidas por ambas partes.
- 7.37. Considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde declarar **FUNDADA** en su totalidad el presente punto controvertido.

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO QUE EL ÁRBITRO ÚNICO DECLARE CONSENTIDA LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO EFECTUADO POR EL CONTRATISTA MEDIANTE CARTA NOTARIAL N° 002-2023-CONSORCIO SUPERVISOR GYM/RLC, RECEPCIONADA POR LA ENTIDAD EL 14 DE JUNIO DE 2023, POR LA CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO DE SU OBLIGACIÓN ESENCIAL DE PAGAR LA VALORIZACIÓN N° 04 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.

Resumen de la posición del DEMANDANTE

- 7.38. La demandante señala que, respecto al fondo o causal de la resolución del contrato, ha ejercido su derecho de resolver el contrato ante el incumplimiento injustificado de pago de la Valorización N° 04 correspondiente al mes de marzo 2023.
- 7.39. Indica también que ha cumplido con seguir el procedimiento indicado en el art. 165 del RLCE, ya que se hizo el apercibimiento de resolución del contrato (Carta Notarial N° 001-2023-CONSORCIO SUPERVISOR GyM/RLC), posteriormente y ante el incumplimiento de la entidad se procedió a resolver el contrato (Carta Notarial N° 002-2023-CONSORCIO

345
Trescientos
Cuarenta y cinco

SUPERVISOR GyM/RLC), por lo tanto, se trata de una resolución de contrato válida y eficaz que surte los efectos legales previstos.

Resumen de la posición del DEMANDADO

- 7.40. La demandada señala que habiendo resuelto primigeniamente el contrato mediante Carta Notarial N° 002-2023-MDH/GM y Resolución de Gerencia Municipal N° 055-2023-MDH/GM, entonces, a partir de ese momento ya no hay obligaciones ni derechos que aten a las partes, por lo que el contrato carecía de efecto legal, no siendo aplicables las causales de resolución del contrato.

Posición definitiva del ARBITRO ÚNICO

- 7.41. Tal como ya indicamos, la resolución del contrato es una forma de terminación anticipada del contrato, y se produce cuanto una de las partes falta al cumplimiento de sus prestaciones, pese haber sido requerido previamente para que subsane su incumplimiento, o se torna imposible, de manera definitiva, su continuación por caso fortuito o fuerza mayor.

- 7.42. En el marco de las pretensiones materia de análisis, la suscrita advierte que es relevante determinar, a efectos de llegar a una conclusión concreta respecto a cada una de las materias sometidas a análisis, si es que se cumplieron las condiciones necesarias para que la resolución contractual sea válida. En este análisis, esta Árbitro Único evaluará las posiciones vertidas por ambas partes, por un lado, la de la entidad que señala que cumplió con sus obligaciones contractuales y que al momento de la resolución del contrato la relación jurídica entre ambas partes era inexistente; y el del contratista, que considera que su contraparte no ha cumplido con su obligación de pago por el servicio efectuado. De manera que, esta Árbitro Único considera necesario, preliminarmente, verificar si, efectivamente, la resolución contractual planteada por el contratista ha cumplido con la formalidad que exige la normativa del caso.

- 7.43. **Respecto al procedimiento de resolución del contrato:** el contratista ha efectuado las siguientes actuaciones:

- Mediante Carta Notarial N° 001-2023-CONSORCIO SUPERVISOR GyM/RLC, recepcionada por la entidad el 29 de mayo de 2023, requirió a la Municipalidad Distrital de Huácar que cumpla con su obligación de pago de la Valorización N° 04 correspondiente al mes de marzo 2023.
- Mediante Carta Notarial N° 002-2023-CONSORCIO SUPERVISOR GyM/RLC, recepcionada por la entidad el 14 de junio de 2023, y ante la reiterada negativa de la

Municipalidad Distrital de Huácar en cumplir con sus obligaciones contractuales, procedió a resolver el contrato en forma total, conforme al artículo 164 y 165 del RLCE.

- 7.44. Conforme a ello, podemos advertir que el contratista ha cumplido con el procedimiento indicado en el artículo 165 del RLCE, ya que se hizo el apercibimiento de resolución del contrato otorgando quince días como mínimo para el cumplimiento de sus obligaciones (Carta Notarial N° 001-2023-CONSORCIO SUPERVISOR GyM/RLC), posteriormente y ante el incumplimiento de la entidad se procedió a resolver el contrato (Carta Notarial N° 002-2023-CONSORCIO SUPERVISOR GyM/RLC), por lo tanto la resolución del contrato efectuada por el contratista si cumple con este requisito.
- 7.45. **Respecto a la justificación de la resolución del contrato:** Habiéndose revisado el cumplimiento formal del procedimiento de resolución contractual por parte del contratista, esta Ábitro Único estima necesario pasar a revisar los hechos ocurridos con posterioridad a la suscripción del contrato, a fin de realizar un análisis en conjunto que pueda determinar si la resolución contractual se encontraba o no debidamente justificada. Para tal efecto, corresponde verificar si es que la decisión de resolver el contrato encuentra su sustento, por lo que, revisadas las razones por las cuales el contratista comunicó a la entidad la resolución contractual, se evidencia que la misma se sustentó en un hecho concreto: **la falta de pago de las valorizaciones**; por lo que, corresponde verificar, si la entidad habría incurrido o no en los incumplimientos descritos por el consorcio que sustentarían la resolución contractual efectuada.
- 7.46. Al respecto, la demandada contradice la presente pretensión basándose en el hecho que habiendo ejercido ella su derecho de resolver el contrato con anterioridad a la resolución efectuada por el contratista, entonces, la relación jurídica existente entre las partes se encontraba extinta; sin embargo y como ya fundamentamos en los numerales 7.27 al 7.36 del presente laudo, la causal invocada por la entidad para la resolución inmediata del contrato era inexistente por cuanto no se había seguido el procedimiento establecido y se había aplicado penalidad por encima del tope máximo establecido por la norma, lo que a su vez implicaba que la Carta Notarial N° 002-2023-MDH/GM y Resolución de Gerencia Municipal N° 055-2023-MDH/GM adolecen de vicios sancionados con la nulidad. Por lo tanto, habiéndose acreditado que la resolución del contrato efectuada por la entidad es nula, entonces, el contrato se mantiene vigente.
- 7.47. Ahora bien, el contratista basa su decisión en una supuesta falta de pago de la Valorización N° 04 correspondiente al mes de marzo de 2023, argumento que no fue contradicho por la entidad quien, contrariamente, basa su defensa en un hecho ya desvirtuado en sede arbitral; asimismo, la realización de una valorización implica la cuantificación económica del avance en el cumplimiento del servicio de supervisión, su

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lloerco
SECRETARÍA ARBITRAL

HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA
ARBITRO ÚNICO

verificación, aprobación y genera la obligación de su pago a cargo de la entidad, por lo tanto, las valorizaciones que se encuentran en trámite al momento de resolverse el contrato contienen deudas expresas y exigibles contraídas por la entidad, cuyo pago es una obligación en forma independiente y autónoma, pues tiene la naturaleza de pago a cuenta.

- 7.48. Entonces, habiéndose determinado que el contratista basa su decisión en la falta de pago y de los medios probatorios aparejados en la demanda se tiene que la Valorización N° 04 fue correctamente tramitada y se ha generado la obligación de pago a cargo de la entidad, por lo que su incumplimiento acarrea la omisión de una obligación esencial que determina la imposibilidad de alcanzar la finalidad esencial del contrato que, en referencia al contratista, le impide gozar de la contraprestación por el servicio efectuado, tal como señala la Opinión N° 003-2021/DTN que dice:

*"... Como se aprecia, la determinación de una obligación como esencial, depende de si ésta es indispensable para alcanzar la finalidad del contrato, siendo necesario que aquella se encuentre establecida en éste. En ese sentido, de acuerdo con la citada opinión, **el pago es la principal obligación esencial a cargo de la Entidad**; sin embargo, pueden existir otras obligaciones esenciales en función a las características y condiciones del contrato. Cabe precisar que en las bases y en el contrato también podrían establecerse obligaciones no esenciales..." (Énfasis agregado)*

Por lo tanto, la resolución del contrato efectuada por el contratista si cumple con este requisito.

49. Conforme a ello, habiéndose acreditado que el contratista ha cumplido con realizar el procedimiento establecido para la resolución del contrato y, además, la causa invocada para ejercitar sus derechos se encuentra debidamente justificada, entonces, corresponde delimitar los efectos que se generan ante una resolución contractual, para lo cual citaremos lo indicado por el numeral 2.2.1 de la Opinión N° 086-2018/DTN que dice:

"... 2.2.1 Tal como se ha indicado al absolver la consulta anterior, si alguna de las partes del contrato falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe requerirla dentro del plazo legal establecido, a través de una carta notarial, bajo apercibimiento de resolver el contrato. En caso la parte requerida persista en su incumplimiento, la parte perjudicada quedará facultada para resolver el contrato, debiendo remitir por vía notarial el documento en el que manifieste tal decisión. De esta manera, el contrato quedará resuelto de pleno derecho una vez que se efectúe la recepción de la referida comunicación.

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Estrada Tabuc
SECRETARÍA ARBITRAL

ARBITRO ÚNICO
Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lúcrecia Leiva Tauri
SECRETARÍA ARBITRAL

Como puede evidenciarse, **la resolución contractual se materializa una vez que la parte requerida recibe la comunicación donde su contraparte (la parte afectada) le informa la decisión de resolver el mismo; por tanto, desde aquel momento, el contrato dejará de surtir efectos y ambas partes - Entidad y contratista- quedarán desvinculadas.**

Sobre este punto, es preciso citar a De La Puente Y Lavalle, quien menciona lo siguiente: "(...) la resolución deja sin efecto la relación jurídica patrimonial, la convierte en ineficaz, de tal manera que ella deja de ligar a las partes en el sentido que ya no subsiste el deber de cumplir las obligaciones que la constituyen ni, consecuentemente, ejecutar las respectivas prestaciones." (El subrayado es agregado).

Por su parte, García de Enterría señala que la resolución "(...) es una forma de extinción anticipada del contrato actuada facultativamente por una de las partes, cuya función consiste en salvaguardar su interés contractual como defensa frente al riesgo de que quede frustrado por la conducta de la otra parte". (El subrayado es agregado).

En virtud de lo expuesto, puede colegirse que si una de las partes (Entidad o contratista) resuelve debidamente un contrato –es decir, siguiendo el procedimiento y cumpliendo los requisitos y formalidades previstas en la normativa de contrataciones del Estado- no cabría la posibilidad de que su contraparte efectuó una nueva resolución respecto del mismo contrato, puesto que para entonces, la relación jurídica ya se encontraría extinta.

Finalmente, cabe precisar que lo señalado líneas arriba no es óbice para que las discrepancias que se generen a raíz de una resolución contractual puedan someterse a los medios de solución de controversias previstos en la normativa de contrataciones del Estado..." (Énfasis agregado)

En esa misma línea, el numeral 2.3 de la referida Opinión N° 086-2018/DTN señala:

"... Ante la resolución del contrato por parte del contratista. ¿Qué procedimiento o procedimientos debe realizar la entidad si considera cuestionar la referida resolución contractual?" (Sic).

2.3.1 Al respecto, el artículo 137 del Reglamento señala "Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles

siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entiende que la resolución del contrato ha quedado consentida..." (El subrayado es agregado).

En ese sentido, cualquier controversia relacionada la resolución del contrato puede ser sometida a conciliación o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de notificada dicha resolución..." (Énfasis agregado)

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Pineda Echevarría Tahir
SECRETARÍA ARBITRAL

7.50. Conforme a ello, ante la resolución de un contrato, la parte afectada se encuentra habilitada para recurrir a los medios de solución de controversias previstos por la norma a fin de hacer valer sus derechos; sin embargo, para el presente caso, de los recaudos del escrito de contestación de la demanda y de lo oralizado en la audiencia de informes orales se tiene que la demandada no ha invocado el sometimiento a conciliación o arbitraje de la resolución del contrato efectuado por el contratista, ni mucho menos a planteado la reconvencción arbitral ante este despacho; por lo que, habiendo transcurrido en demasía el plazo con el que contaba la entidad para incoar tales medios de solución de controversias, se advierte que su derecho habría caducado a causa de la inactividad del titular, tanto más si el propio contratista mediante Carta N° 133-2023-CONSORCIO.SUPERVISOR.GyM/RLC, notificada a la entidad el 22 de setiembre de 2023, hizo saber a su contraparte sobre dicha situación legal; por todo lo expuesto, corresponde declarar consentida la resolución del contrato efectuada por el contratista, al no haberse interpuesto recurso alguno contra esta.

7.51. Considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde declarar **FUNDADA** en su totalidad el presente punto controvertido.

CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO QUE EL ÁRBITRO ÚNICO ORDENE A LA DEMANDADA EL PAGO A FAVOR DEL DEMANDANTE DE LA SUMA DE S/ 323,824.48 (TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 48/100 SOLES), POR CONCEPTO DE REEMBOLSO Y/O REINTEGRO DE VALORIZACIONES ADEUDADAS, INDEBIDAMENTE DESCONTADOS POR LA ENTIDAD DEMANDADA.

Resumen de la posición del DEMANDANTE

7.52. La demandante señala que, habiéndose determinado que la entidad ha procedido de forma irregular y arbitraria al aplicarle "otras penalidades" sin observar el debido procedimiento ni los requisitos establecidos para su procedencia, corresponde que la Resolución de Gerencia Municipal N° 054-2023-MDH/GM de fecha 09 de junio de 2023 y la

Carta Notarial N° 001-2023-MDH/GM, sean declaradas nulas y sin efectos legales, ello origina a su vez el derecho de restituir, rembolsar y/o devolver al contratista el monto indebidamente retenido de las valorizaciones con cargo a la aplicación de dicha penalidad, ya que su aplicación contraviene las normas y el orden público, además que constituye un derecho del contratista recibir la contraprestación por el trabajo efectivamente ejecutado y exigir su cumplimiento a través de los mecanismos previstos por la Ley y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Resumen de la posición de la DEMANDADA

- 7.53. La demandada solicita que el tribunal arbitral ordene la retención de las valorizaciones para ser descontado por la acumulación de penalidades.
- 7.54. Señala también que de comprobarse la correcta aplicación de penalidades y la resolución del contrato de supervisión no corresponderá el reintegro del monto pretendido, teniendo en cuenta que dicha retención se hizo con la finalidad de salvaguardar los intereses del estado.

Posición definitiva del ARBITRO ÚNICO

- 7.55. Ahora bien, el presente punto controvertido esta referido al supuesto derecho de pago que se ha originado a favor de la demandante, en virtud de una obligación nacida de un contrato administrativo y cuya fuerza estriba en el incumplimiento de su contraparte, nos encontramos pues frente a obligaciones reciprocas, las cuales, a criterio de ARNAU MOYA⁴, implica que los deberes de prestación se encuentran ligados entre sí por un nexo de interdependencia puesto que cada parte acepta el sacrificio que para ella supone la prestación que le incumbe, puesto que su finalidad es lograr como resultado la prestación que la otra parte debe realizar. Este nexo que existe entre la obligación recíproca se denomina sinalagma, de aquí que a esta obligación también se le conozca con el nombre de sinalagmática.

- 7.56. Así pues, tratándose de prestaciones reciprocas si bien es obligación del proveedor ejecutar las prestaciones pactadas a favor de la Entidad, es también obligación de la Entidad cumplir con las obligaciones que ha asumido; entre estas, el pago de la respectiva contraprestación al contratista; tal como ha señalado la Opinión N° 116-2016/DTN en su numeral 2.2, que dice:

“...Al respecto, debe precisarse que, si bien en los contratos celebrados bajo el ámbito de la normativa de contrataciones del Estado prima el interés

⁴ ARNAU MOYA, Federico. Lecciones de Derecho Civil II, Obligaciones y Contratos. Publicacions de la Universitat Jaume I. Pág. 27-28.
<https://libros.metabiblioteca.org/server/api/core/bitstreams/20ac8d27-7352-4d67-b040-fb0aef6f11d8/content>

público, ello no afecta el hecho que, desde la perspectiva del contratista, el interés en participar en una contratación estatal sea el de obtener una retribución económica (pago) a cambio de las prestaciones que ejecute.

Tal hecho no ha sido soslayado por la normativa de contrataciones del Estado, sino que, por el contrario, es reconocido en los artículos 39 de la Ley y 149 del Reglamento, al apreciarse la relación que existe entre las prestaciones que debe ejecutar el contratista y la correspondiente contraprestación o pago que debe efectuar la Entidad por ellas.

De esta manera, la normativa de contrataciones del Estado reconoce que los proveedores son agentes de mercado que colaboran con las Entidades al satisfacer sus necesidades de abastecimiento de bienes, servicios y obras para el adecuado cumplimiento de sus funciones; no obstante, dicha colaboración implica el pago del precio de mercado de la prestación, el mismo que debe incluir todos los costos necesarios para su ejecución..."

7-57. Entonces, tratándose de obligaciones recíprocas vinculadas en razón de un contrato administrativo, en lo concerniente al contratista se ha generado el derecho de recibir la contraprestación convenida por lo realmente ejecutado, ya que en palabras de ARNAU MOYA⁵:

"... La palabra pago se relaciona con el cumplimiento de las obligaciones dinerarias. Sin embargo, jurídicamente pago y cumplimiento son términos equivalentes que se refieren a la realización por el deudor del cumplimiento previsto en la obligación (Bercovitz, 2004). El pago presupone una obligación anterior puesto que, en otro caso, el pago sin una obligación previa, nos encontraríamos ante un supuesto de cobro de lo indebido (ex art. 1.895 cc) (Pérez Álvarez, 2000). El propio Código utiliza en numerosas ocasiones las expresiones pago y cumplimiento como equivalentes. El término incumplimiento es el reverso de la expresión cumplimiento. El cumplimiento o pago es la realización de la prestación debida que trae como consecuencia (Pérez Álvarez, 2000):

- La extinción de las obligaciones. Si bien las obligaciones también se extinguen por otras causas.
- La liberación del deudor. Lo que supone que desaparece el deber jurídico de llevar a cabo la prestación.

⁵ ARNAU MOYA, Federico. Lecciones de Derecho Civil II, Obligaciones y Contratos. Publicacions de la Universitat Jaume I. Pàg. 44.
<https://libros.metabiblioteca.org/server/api/core/bitstreams/20ac8d27-7352-4d67-b040-fb0aef6f11d8/content>

- La satisfacción del interés del acreedor. Puesto que el cumplimiento supone la consecución de la prestación que se le podía exigir al deudor.

El cumplimiento puede ser «voluntario» y «forzoso», en este último caso hace referencia al cumplimiento que se impone de forma coactiva al deudor cuando no cumple de forma voluntaria (Pérez Álvarez, 2000).

El cumplimiento forzoso supone que previamente el acreedor ante el incumplimiento del deudor se ha visto obligado a acudir a la vía judicial, obteniendo una sentencia en la que se condena a aquel a cumplir forzosamente...

7.58. Para el presente caso, este tribunal arbitral ha determinado previamente que tanto la Resolución de Gerencia Municipal N° 054-2023-MDH/GM como la Carta Notarial N° 001-2023-MDH/GM, ambas adolecen de la debida motivación sancionada con la nulidad, entonces, se ha enervado o restaurado nuevamente el derecho del demandante en obtener la contraprestación por los servicios efectivamente ejecutados y contenidos en la valorización debidamente aprobada, valorización que al tener la naturaleza de pago a cuenta- según el artículo 166 del RLCE- implica adelantar de manera anticipada antes de realizar el abono de una deuda final, entonces, se ha generado la obligación de la demandada de abonar a favor del demandante, el monto retenido o descontado por concepto de penalidades, como consecuencia de la Resolución de Gerencia Municipal N° 054-2023-MDH/GM, anulada en sede arbitral.

7.59. Finalmente, de los medios probatorios ofrecidos por la demandante se tiene que el resumen de los montos adeudados por la demandada por concepto de valorizaciones impagas es el siguiente:

cálculo de la deuda: Valorizaciones pendiente de pago y devolución de garantía de fiel cumplimiento	valorizaciones cobradas				valorización con pago parcial		valorizaciones tramitadas sin pago		valorización pendiente de trámite	total
	Dic 22	Ene 23	Feb 23	Mar 23	Abr 23	May 23	Jun 23	total		
Liquidado a cobrar	12,616.21	130,367.46	117,751.26	130,367.46	126,162.06	130,367.16	17,848.62	685,480.53		
Pagado	12,616.21	130,367.46	117,751.26	15,844.00	0.00	0.00	0.00	276,378.93		
Retención indebida	0.00	0.00	0.00	85,277.12	0.00	0.00	0.00	85,277.12		
Retención por garantía FC contrato principal	2,849.64	29,446.28	26,596.64	29,446.28	28,496.29	29,446.28	8,548.89	154,830.29		
Por devolución pendiente de pago	0.00	0.00	0.00	114,723.46	126,162.06	130,367.46	17,848.62	323,824.48		
Desvoluc. Retención Garantía de Fiel cumplimiento										196,574.00
Total (valoriz. Pendiente de pago + dev. Garantía)										520,398.48

Siendo que, además, la demandada no ha cuestionado ni objetado el monto de dicha deuda, ni mucho menos ha desvirtuado el concepto de las mismas, razón por la que la suscrita tiene por ciertos los montos postulados por la demandante.

- 7.60. Considerando lo hasta aquí expuesto y dado que tanto la Resolución de Gerencia Municipal N° 054-2023-MDH/GM como la Carta Notarial N° 001-2023-MDH/GM carecen de valor jurídico y legal, lo que a su vez implica reponer el derecho de pago a favor del demandante por las prestaciones ejecutadas a favor del demandado, entonces, corresponde declarar **FUNDADO** el presente punto controvertido en todos sus extremos.

QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO QUE EL ÁRBITRO ÚNICO ORDENE A LA DEMANDADA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUÁCAR, LA ENTREGA A FAVOR DEL DEMANDANTE DEL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, CONFORME A LA CLÁUSULA DÉCIMA DEL CONTRATO N° 001-2022-MDH/A.

Resumen de la posición del DEMANDANTE

- 7.61. Señala que, la entidad es responsable de emitir la Conformidad de Prestación del Servicio, incluso de los contratos resueltos, ya que en este caso se otorga la conformidad por la parte de la prestación efectivamente ejecutada, ya que durante la recepción de la obra no se ha producido observaciones respecto a las prestaciones de la supervisión

Resumen de la posición de la DEMANDADA

- 7.62. Señala que en caso se realice la resolución total del contrato debido al incumplimiento del contratista, no correspondería otorgar la conformidad, situación que si se cumple en el presente caso ya que nos encontramos frente a una resolución total del contrato.

Posición definitiva del ARBITRO ÚNICO

- 7.63. Que, la Opinión N° 008-2022/DTN señala:

"... Como se señaló al absolver la consulta anterior, para dar la conformidad de las prestaciones ejecutadas por el contratista, en el marco de los contratos celebrados al amparo de la normativa de contrataciones del Estado, **se requiere que la Entidad realice la verificación del cumplimiento de todas las obligaciones contractuales pactadas**, siendo que en el caso de contrataciones perfeccionadas mediante una orden de compra o de servicio, el numeral 168.2 del artículo 168 del Reglamento ha previsto la posibilidad de que luego de la verificación efectuada, la conformidad conste en dicho documento, sin perjuicio de lo señalado, la entidad puede decidir que en estos casos la conformidad conste en un informe del área usuaria..." (Énfasis agregado)

7.64. Por su parte, la cláusula décima del contrato indica:

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el contenido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar. Este procedimiento no resulta aplicable cuando las consultorías manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

7.65. Conforme a ello, la entrega del Certificado de Conformidad por la Prestación del Servicio resulta ser un acto a cargo de la entidad, previa verificación por parte del funcionario responsable del área usuaria de la contratación de la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, y que para el contratista determina contar con el documento que acredite el cumplimiento de sus prestaciones conforme a las características y condiciones requeridas por la entidad contratante; ahora bien, siguiendo a MORÓN URBINA y AGUILERA B.⁶, podemos definir a la Conformidad de la Prestación como el acto de control a cargo del área usuaria por la que esta expresa la comprobación favorable de la cantidad y calidad de las prestaciones comprometidas por el contratista- bienes entregados, funcionamiento, rendimiento, medición de la obra, calidad del servicios- previa realización de las pruebas necesarias. La Conformidad de la Prestación produce los siguientes efectos:

- Activa el mecanismo para el proceder al pago al contratista
- Aprueba las prestaciones realizadas en su favor, incluso si hubiera modificaciones o incremento de prestaciones.
- Libera de los posibles vicios o defectos manifiestos en la prestación, salvo los reclamos por vicios ocultos.

7.66. De la misma forma, MORÓN URBINA y AGUILERA B.⁷ señalan que los derechos del contratista frente a la entidad contratante son, entre otros:

- A percibir el precio pactado o la retribución convenida luego de haber ejecutado su prestación y obtenido la respectiva conformidad, como regla general, y en caso de

⁶ MORÓN URBINA, Juan Carlos y AGUILERA B., Zita. Aspectos Jurídicos de la Contratación Estatal- Colección Lo Esencial del Derecho N° 9. Fondo Editorial de la PUCP. 1° Edición. Lima-Perú. 2017. Pág. 156.

⁷ Ob. Cit. Pág. 157.

retrasos, al cobro de intereses legales desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

- 7.67. Conforme a ello, la obtención de la Conformidad de la Prestación constituye un derecho del contratista frente a la ejecución de sus obligaciones contractuales; ahora bien, y que sucede con la Conformidad de la Prestación en caso se haya resuelto el contrato por causas no atribuibles al contratista- como ya quedó demostrado precedentemente-, al respecto debemos remitirnos a la Opinión N° 001-2019/DTN (invocada por la entidad) que dice:

" ...

- 3.1 Corresponde a la parte afectada por el incumplimiento determinar si, en el marco del procedimiento de resolución del contrato previsto en el artículo 136 del Reglamento, la resolución será total o parcial. La resolución parcial sólo involucrará a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento cuando dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, debería ser indicada expresamente en el documento que comunica la resolución del contrato y será viable siempre que la resolución del total del contrato pudiera afectar los intereses de la Entidad.
- 3.2 Cuando un contrato ha sido resuelto –total o parcialmente- por causas imputables al contratista, y esta resolución ha quedado consentida, la Entidad se encuentra facultada para ejecutar, en su totalidad, la garantía de fiel cumplimiento que se hubiere otorgado, sin tener en cuenta la naturaleza de la prestación incumplida que motivó dicha resolución.
- 3.3 Cuando un contrato ha sido resuelto de manera parcial, conforme a las condiciones previstas en el artículo 136 del Reglamento, la Entidad procederá según lo previsto en el artículo 143 del Reglamento, realizando –cuando corresponda- la recepción y conformidad de las prestaciones parciales ejecutadas por el contratista, cuando se verifique el cumplimiento de las condiciones contractuales. **Por otro lado, en caso se realice la resolución total del contrato debido al incumplimiento del contratista, no correspondería otorgar tal conformidad.**
- 3.4 Otorgada la conformidad, y dentro de los quince (15) días calendario de emitida, la Entidad debe efectuar al pago al contratista por la contraprestación pactada, conforme lo establece el artículo 149 del Reglamento..." (Énfasis agregado)

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Echevarría Tafur
SECRETARÍA ARBITRAL

Heidi Ivonne Torres Santos de Kuleza
ARBITRO ÚNICO

7.68. Entonces, la jurisprudencia en la materia nos explica claramente que en caso se realice la **resolución total** del contrato debido al **incumplimiento del contratista**, no correspondería otorgar tal conformidad, de lo que se desprende que, *contrario sensu*, en caso se realice la **resolución total del contrato** debido a **otras circunstancias no atribuibles al contratista**, si correspondería otorgar la indicada conformidad, máxime si tenemos en cuenta que dicha formalidad constituye un derecho del contratista que le permite activar el mecanismo para proceder a su pago, aprueba las prestaciones realizadas en su favor, incluso si hubiera modificaciones o incremento de prestaciones, y libera de los posibles vicios o defectos manifiestos en la prestación, salvo los reclamos por vicios ocultos.

7.69. Finalmente, habiéndose determinado que sí corresponde que la entidad emita el Certificado de Conformidad por la Prestación del Servicio a favor del contratista, también debemos de precisar que el mismo deberá de abarcar a las prestaciones efectivamente ejecutadas y aprobadas mediante las valorizaciones mensuales que se hubieran presentado hasta antes de la resolución del contrato (diciembre-2022, enero-2023, febrero-2023, marzo-2023, abril-2023, mayo-2023 y junio-2023), debiendo considerarse el porcentaje del avance del contrato de supervisión conforme al siguiente detalle:

valorizaciones cobradas			valorización con pago parcial	valorizaciones tramitadas sin pago		valorización pendiente de trámite	total
Dic 22	Ene 23	Feb 23	Mar 23	Abr 23	May 23	Jun 23	total
12,616.21	130,367.46	117,751.26	130,367.46	126,162.06	130,367.46	37,848.62	685,480.53
12,616.21	130,367.46	117,751.26	15,644.00	0.00	0.00	0.00	276,378.93
0.00	0.00	0.00	85,277.12	0.00	0.00	0.00	85,277.12
2,849.64	29,446.28	26,596.64	29,446.28	28,496.29	29,446.28	8,548.89	154,830.29
0.00	0.00	0.00	114,723.46	126,162.06	130,367.46	37,848.62	323,824.48

7.70. Considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde declarar **FUNDADO** el presente punto controvertido en todos sus extremos.

SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO QUE EL ÁRBITRO ÚNICO ORDENE A LA DEMANDADA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUÁCAR LA DEVOLUCIÓN Y/O PAGO A FAVOR DEL DEMANDANTE DE LA SUMA DE S/ 196,574.00 (CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES), ENTREGADOS COMO GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO SEGÚN LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA Nº 001-2022-MDH-A.

Resumen de la posición del DEMANDANTE

- 7.71. Señala que, habiéndose originado la obligación de la entidad de emitir la conformidad de prestación del servicio, esto a su vez origina la obligación de la entidad de devolver al contratista la garantía otorgada para la firma del contrato, constituida por el 10% de retención del valor del contrato

Resumen de la posición de la DEMANDADA

- 7.72. Señala la demandada que la garantía de fiel cumplimiento no puede ser devuelta porque el contrato se encuentra resuelto por la entidad, salvo que al momento de laudarse se resuelva de diferente manera.

Posición definitiva del ARBITRO ÚNICO

- 7.73. Tal como ya indicamos en los numerales 7.41 al 7.50 del presente laudo, la resolución efectuada por la entidad adolece de vicios insubsanables sancionados con la nulidad, razón por la cual se procedió a revisar el procedimiento y la justificación para la resolución efectuada por el contratista, habiéndose determinado que la misma si cumple con los requisitos y condiciones previstos por la norma para su procedencia, por lo tanto, la misma ha sido declarada consentida en sede arbitral; ahora bien, una de las consecuencias inmediatas del consentimiento de la resolución del contrato esta referida a la obligación de LA ENTIDAD de devolver y/o liberar la Garantía de Fiel cumplimiento otorgada por EL CONTRATISTA para la suscripción del contrato - que para nuestro caso está constituida por el Fondo de Retención del 10% del monto contractual-, hecho que se encuentra claramente descrito en el numeral 149.1 del Artículo 149 del RLCE que dice:

"... 149.1. Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. **Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación** a cargo del contratista, en el caso de bienes, **servicios en general** y consultorías en general, o hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de ejecución y consultoría de obras..."
(Énfasis agregado)

- 7.74. Así también, la Opinión N° 090-2021/DTN señala:

"... Como se aprecia, la garantía de fiel cumplimiento constituye un requisito indispensable para el perfeccionamiento del contrato; así, el postor ganador debe entregarla a la Entidad por una suma equivalente al

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Echevarría Tafur
SECRETARÍA ARBITRAL

HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULEZA
ARBITRO ÚNICO

10% del monto del contrato original, siendo que **dicha garantía debe mantenerse vigente durante todo el período de la ejecución contractual, hasta la conformidad de la recepción de la prestación contratada (cuando el objeto sea la entrega de bienes o la prestación de servicios en general y consultorías en general, respectivamente).**

De esta manera, se advierte que la garantía de fiel cumplimiento busca cautelar el correcto y oportuno cumplimiento del íntegro de las obligaciones que son parte del contrato, y no sólo garantizar el cumplimiento de alguna o algunas prestaciones que comprenda dicho contrato.

Por lo tanto, si una contratación de servicios –distintos a los de consultoría de obra- involucrara una serie de prestaciones a cargo del contratista, este debe respaldar el cumplimiento del total de sus obligaciones contractuales a través de una garantía de fiel cumplimiento, la cual **debe mantenerse vigente hasta la conformidad por la cabal ejecución del total de las prestaciones a su cargo**, por un monto equivalente al 10% del contrato; en esa medida, dicho monto respalda un eventual incumplimiento de las obligaciones del contratista y el perjuicio ocasionado por este, independientemente del porcentaje de ejecución de tales prestaciones..."
(Énfasis agregado)

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
"CORPORACIÓN IMPERIUM"
Gabriela Lucero Echevarría Talu
SECRETARÍA ARBITRAL

7.75. Siendo así, al haber adquirido la resolución del contrato efectuada por el contratista la calidad de consentida, esto origina a su vez la obligación de la entidad de devolver y/o liberar la Garantía de Fiel Cumplimiento otorgada para el perfeccionamiento del contrato, por cuanto ha desaparecido la causal para mantenerla vigente ya que se ha cumplido con la ejecución de la prestación, por lo que ya no queda nada que resguardar, salvo los posibles vicios ocultos que pudieran originarse los cuales tienen un propio procedimiento.

7.76. Considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde declarar **FUNDADA** el presente punto controvertido en todos sus extremos.

SÉPTIMO PUNTO CONTROVERTIDO

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO QUE EL ÁRBITRO ÚNICO ORDENE A LA DEMANDADA EL PAGO A FAVOR DEL DEMANDANTE DE UNA INDEMNIZACIÓN POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE: I) POR LA ILEGAL RESOLUCIÓN DEL CONTRATO SUB MATERIA REALIZADA CON

331
DOSCIENTOS
TRINTA Y UNO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°055-2023-MDH/GM; Y II) POR LA ILEGAL EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO; INDEMNIZACIÓN QUE ALCANZA HASTA POR LA SUMA DE S/ 279,667.95 (DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 95/100 SOLES), MÁS INTERESES GENERADOS, CONFORME AL NUMERAL 36.2 DEL ARTÍCULO 36° DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, CONCORDANTE CON EL NUMERAL 166.2 DEL ARTÍCULO 166° DE SU REGLAMENTO.

Resumen de la posición del DEMANDANTE

- 7.77. Señala que el pago de la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por la entidad se encuentra reconocidos y regulados por el numeral 36.2 del Artículo 36 de la LCE, concordante con el numeral 166.2 del artículo 166 del RLCE, razón por la cual se le debe indemnizar por el lucro cesante y daño moral que se le ha ocasionado.

Resumen de la posición de la DEMANDADA

- 7.78. Señala que se ratifica en la legalidad de la resolución del contrato efectuada por dicha parte, por causa atribuible al contratista y que no da lugar a una indemnización por daños y perjuicios.

Posición definitiva del ARBITRO ÚNICO

- 7.79. Cabe precisar en primer lugar que, a efectos de emitir un laudo en forma integral y adecuada, es conveniente mencionar primigeniamente que el daño como elemento constitutivo clave en el análisis materia¹² de un caso de responsabilidad civil, supone siempre el acaecimiento de un hecho que lesiona un interés jurídicamente protegido, provocando siempre un perjuicio y generando consecuencias negativas en la esfera jurídica de un sujeto de derecho, ya sean estas de contenido patrimonial o no.
- 7.80. Por lo tanto, cada vez que nos encontremos frente a un daño resarcible, que cumpla con los requisitos de certeza, subsistencia, especialidad e injusticia, y concurren a su vez los otros elementos configuradores de responsabilidad civil (hecho generador, relación de causalidad y criterio de imputación), se activará la tutela resarcitoria, como mecanismo de defensa frente al sufrimiento de un daño injusto, la que siempre debe expresarse en términos económicos o patrimoniales (indemnización), sea cual fuere la naturaleza del daño.

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Enciso Echevarría Tahir
SECRETARÍA ARBITRAL

HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA
ARBITRO ÚNICO

- 7.81. En este punto del análisis, resulta útil traer a colación lo expuesto por el profesor FELIPE OSTERLING PARODI⁸, quien precisa respecto del daño emergente y lucro cesante lo siguiente:

"... Las pérdidas que sufre el acreedor como consecuencia de la inejecución de la obligación corresponden al daño emergente y las utilidades que deja de percibir, con motivo de la misma inejecución, corresponden al lucro cesante. El daño emergente es el empobrecimiento del patrimonio del acreedor. El lucro cesante corresponde al legítimo enriquecimiento que se frustró (artículo 1321 del Código Civil) ..." (Énfasis agregado)

- 7.82. Concretamente, se tiene que existe una relación intrínseca entre el daño emergente y lucro cesante. Teniendo en cuenta lo expresado, para que exista un lucro cesante debe de existir un daño emergente, es decir la persona que sufre el evento dañoso se ha debido de ver empobrecido o haber perdido un determinado bien y es a raíz de dicha situación que se debe de reparar lo dejado de percibir, que se define como lucro cesante, que no es más que las utilidades dejadas de percibir de no haber sucedido el daño producido.

- 7.83. Asimismo, los daños que se busca resarcir, ya sea daño emergente, lucro cesante o daño moral deben de estar evidentemente acreditados y corroborados en la realidad, no pudiendo determinarse éstos en base a proyecciones de situaciones no ocurridas; así las cosas, se evidencia de la documentación obrante en autos que la demandante ha invocado el reconocimiento del Daño Patrimonial, en su forma de Lucro Cesante, y también el Daño Extrapatrimonial, en su forma de Daño Moral.

- 7.84. Ahora, respecto al Daño Patrimonial, la demandante ha ofrecido como medio probatorio el mérito del Informe Pericial Contable N° 022-2023-REA de fecha 22 de setiembre de 2023, elaborado por Contador Público Colegiado, el mismo que no ha sido refutado o contradicho por la demandada y que ha determinado una afectación patrimonial de la siguiente manera:

"... De los cálculos se desprende que se dejó de percibir por LUCRO CESANTE por S/ 229,667.95 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 95/100 SOLES) que incluye las utilidades dejadas de percibir a consecuencia de la irregular resolución del contrato por parte de la Municipalidad Distrital de Huácar y también incluye la retención indebida de la garantía de fiel cumplimiento.

⁸ OSTERLING PARODI; FELIPE. La Indemnización de Daños y Perjuicios. Artículo publicado en el portal electrónico (web): <http://www.osterlingfirm.com/Documentos/articulos/La%20indemnizacion%20de%20da%C3%B1os.pdf>.

329
tres cientos veintinueve

En aplicación de las normas que establecen el procedimiento de peritaje de parte, este es el monto que se dejó de percibir a consecuencia de la resolución del contrato..." (Énfasis agregado)

- 7.85. Siendo así, la suscrita considera que el Daño Patrimonial, en su forma de Lucro Cesante, reclamado por la demandante, se encuentra debidamente acreditado y corroborado en

la realidad, razón por la cual corresponde que se le imponga a la demandada el pago por tal concepto según el monto indicado en el Informe Pericial Contable N° 022-2023-REA, así como los intereses legales que se hayan generado, tal como señala el numeral 36.2 del Artículo 36 de la LCE que dice:

*"... 36.2 Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, **se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados**. No corresponde el pago de daños y perjuicios en los casos de corrupción de funcionarios o servidores propiciada por parte del contratista, de conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la presente Ley..." (Énfasis agregado)*

De igual forma, el numeral 166.2 del artículo 166 del RLCE también indica:

"... Artículo 166. Efectos de la resolución

166.1. Si la parte perjudicada es la Entidad, esta ejecuta las garantías que el contratista hubiera otorgado sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños irrogados.

166.2. Si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad reconoce la respectiva indemnización por los daños irrogados, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad ..." (Énfasis agregado)

- 7.86. Ahora, respecto al Daño Extrapatrimonial, en su forma de Daño Moral, la demandante ofrece como medio probatorio la CASACIÓN N° 2084-2015/LIMA emitido por la Corte Suprema de Justicia de la República, sin embargo, a criterio de la suscrita dicha jurisprudencia no obliga al juzgador a presumir en todos los casos la existencia del daño moral, pues la propia casación indica que dicha presunción es en "casos puntuales" y dada las "características de cada caso en concreto"; por lo tanto, consideramos que en este extremo de la pretensión indemnizatoria, la demandante no ha probado el resarcimiento solicitado, ya que en su línea argumentativa se limita a señalar literalmente las razones por las que debe ser resarcido, pero no aporta materia probatoria para la cuantificación y atribución del daño del cual ha sido objeto; en ese sentido, no resulta amparable el reconocimiento del daño moral.

- 7.87. Considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde declarar **FUNDADA EN PARTE** el presente punto controvertido, debiendo reconocerse la indemnización solo por el Daño Patrimonial, en su forma de Lucro Cesante.

OCTAVO PUNTO CONTROVERTIDO

DETERMINAR A CUÁL DE LAS PARTES PROCESALES CORRESPONDE ATRIBUIR EL PAGO DE LA TOTALIDAD DE LAS COSTAS Y COSTOS DEL PROCESO ARBITRAL.

Resumen de la posición del DEMANDANTE

- 7.88. Señala que, puesto que el convenio arbitral no señala expresamente quien asumirá las costas y costos del proceso, corresponde que se imponga el pago hacia la entidad, tanto más, si el artículo 166° del RLCE señala: "si la parte perjudicada es el contratista, La Entidad debe reconocerle la respectiva indemnización por los daños irrogados".

Resumen de la posición de la DEMANDADA

- 7.89. La demandada solicita acogerse al numeral 31 de las reglas del proceso arbitral establecidas en el acta de instalación de tribunal arbitral, en el sentido que será el árbitro único quien deberá de determinar hacia cual de las partes se le atribuirá asumirla.

Posición definitiva del ARBITRO ÚNICO

- 7.90. En lo que respecta al presente punto controvertido, es necesario señalar que la regla general dicta que la asunción de costos y gastos arbitrales lo efectúa la parte vencida, debido que por su accionar indebido o irregular se tiene por consecuencia el proceso arbitral, ello es de conformidad al numeral 1 del artículo 73° del Decreto Legislativo N° 1071, que señala:

"... Artículo 73.- Asunción o distribución de costos.

1. El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes. **A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida.** Sin embargo, el tribunal arbitral podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

327
Presuntos
reintegrados

2. Cuando el tribunal arbitral ordene la terminación de las actuaciones arbitrales por transacción, desistimiento, declaración de incompetencia o por cualquier otra razón, fijará los costos del arbitraje en su decisión o laudo.

3. El tribunal arbitral decidirá también los honorarios definitivos del árbitro que haya sido sustituido en el cargo, de acuerdo al estado de las actuaciones arbitrales, en decisión definitiva e inimpugnable..." (Énfasis agregado)

- 7.91. Por otro lado, el Reglamento del centro de arbitraje en su artículo 103, en cuanto a los costos y gastos arbitrales, establece las siguientes disposiciones:

"... Distribución de los costos arbitrales
Artículo 103°.-

Los árbitros se pronunciarán en el laudo que pone fin a la controversia sobre la imputación de los costos del arbitraje, atendiendo a lo establecido en el convenio arbitral. **De no existir acuerdo al respecto, los costos serán de cargo de la parte que haya sido vencida en el arbitraje.**

Sin perjuicio de ello, los árbitros podrán disponer la distribución de los costos del arbitraje entre las partes, si lo considera atendible de acuerdo a lo ocurrido en el arbitraje..." (Énfasis agregado)

- 7.92. De igual forma, los numerales 31 y 32 del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral, establecen:

"... 31. En caso de que una de las partes asumiera el pago de los anticipos de honorarios y gastos administrativos ante la renuencia o demora de la otra, la que ha pagado tendrá derecho a repetir, debiendo comunicar de este hecho, a fin de que el Tribunal Arbitral se pronuncie al momento de laudo, con el reembolso de los mismos más los intereses legales respectivos, esto último solo se resolverá a petición de parte.

32. Sin perjuicio que el Tribunal Arbitral pueda establecer que **el pago del íntegro de las costas y costos corresponda a la parte vencida en el arbitraje...**" (Énfasis agregado)

- 7.93. Atendiendo a lo expuesto, se debe tener en cuenta que el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral ha otorgado la potestad al Árbitro Único de determinar en el Laudo Arbitral el sentido de la condena respecto de los costos y gastos arbitrales, así como los conceptos que se deben considerar como tales.

- 7.94. Siendo ello así, en el presente proceso arbitral, se han presentado cuatro pretensiones principales, incluyendo la presente, evidenciándose que la demandada ha sido la responsable de las consecuencias jurídicas del presente proceso, lo que a su vez ha

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabiela Lucero Echevarría Tafur
SECRETARÍA ARBITRAL

ARBITRO ÚNICO

originado que el demandante tenga que recurrir ante sede arbitral para enervar su derecho, por lo que en aplicación del numeral 1 del artículo 73° del Decreto Legislativo N° 1071, este tribunal considera atendible imputar sobre la demandada el 100% de la obligación de pago de las costas y costos arbitrales, precisándose que al haber efectuado la demandante el pago de la totalidad de los mismos, entonces, corresponde que se le reembolse la suma de S/ 16,000.00 (Dieciséis Mil con 00/100 Soles).

7.95. Considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde declarar **FUNDADO** el presente punto controvertido en todos sus extremos.

8. PARTE RESOLUTIVA:

Estando a las consideraciones expuestas, dentro del plazo correspondiente, la Árbitro Único, en uso de sus facultades y conforme a lo ordenado en la Constitución Política del Estado se emite el Laudo de Derecho:

PRIMERO. – DECLARAR FUNDADA la primera pretensión principal, en consecuencia, **SE DECLARA NULA y SIN EFECTO LEGAL** la Resolución de Gerencia Municipal N° 054-2023-MDH/GM de fecha 09 de junio de 2023 y la Carta Notarial N° 001-2023-MDH/GM, emitidas por la demandada, por la que resuelven aplicar penalidades contra el contratista en la suma de S/ 552,000.00; (QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL Y 00/100); asimismo, **DECLÁRESE ABSUELTO** al contratista de la comisión de las penalidades indicadas en la Resolución de Gerencia Municipal N° 054-2023-MDH/GM y en el Informe N° 109-2023-MDH/SGLSGYA/NJQ de fecha 09 de junio de 2023.

SEGUNDO. – DECLARAR FUNDADA la segunda pretensión principal, en consecuencia, **SE DECLARA NULA y SIN EFECTO LEGAL** la Resolución de Gerencia Municipal N° 055-2023-MDH/GM de fecha 09 de junio de 2023 y la Carta Notarial N° 002-2023-MDH/GM, mediante las cuales la Municipalidad Distrital de Huácar resuelve unilateralmente el Contrato N° 001-2022-MDH/A, por contravenir las normas y el orden público.

TERCERO. - DECLARAR FUNDADA la tercera pretensión principal, en consecuencia, **SE DECLARA CONSENTIDA** la **RESOLUCIÓN DEL CONTRATO** efectuado por el contratista mediante Carta Notarial N° 002-2023-CONSORCIO SUPERVISOR GyM/RLC, recepcionada por la entidad el 14 de junio de 2023, por las consideraciones previamente expuestas en autos.

CUARTO. - DECLARAR FUNDADA la pretensión accesoria a la primera pretensión principal, en consecuencia, **SE ORDENA** a la Municipalidad Distrital de Huácar que realice el pago a favor del demandante de la suma de S/ 323,824.48 (**TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 48/100 SOLES**), por concepto de reembolso y/o reintegro de valorizaciones adeudadas.

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN
"CORPORACIÓN IMPERIUM"
Gabinete de la Secretaría Arbitral
SECRETARÍA ARBITRAL

ARBITRO ÚNICO
Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza

QUINTO. - DECLARAR FUNDADA la primera pretensión accesoria a la tercera pretensión principal, en consecuencia, **SE ORDENA** a la Municipalidad Distrital de Huácar que realice **LA ENTREGA** a favor del demandante del Certificado de Conformidad por la Prestación del Servicio, conforme a la cláusula décima del Contrato N° 001-2022-MDH/A, el mismo que deberá de abarcar el porcentaje de avance real del contrato de supervisión, conforme a las prestaciones efectivamente ejecutadas y aprobadas mediante las valorizaciones de diciembre-2022, enero-2023, febrero-2023, marzo-2023, abril-2023, mayo-2023 y junio-2023.

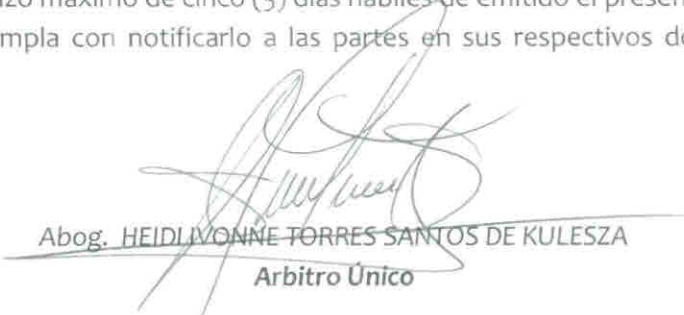
SEXTO. - DECLARAR FUNDADA la segunda pretensión accesoria a la tercera pretensión principal, en consecuencia, **SE ORDENA** a la Municipalidad Distrital de Huácar que realice la **DEVOLUCIÓN Y/O PAGO** a favor del demandante de la suma de **S/ 196,574.00 (CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES)**, por concepto de Garantía de Fiel Cumplimiento en su modalidad de Fondo de Retención del 10% del monto del contrato.

SÉPTIMO - DECLARAR FUNDADA EN PARTE la tercera pretensión accesoria a la tercera pretensión principal, en consecuencia, **SE ORDENA** a la Municipalidad Distrital de Huácar que realice **EL PAGO** a favor del demandante de una indemnización por daños y perjuicios, en la suma de **S/ 229,667.95 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 95/100 SOLES)** más los intereses legales generados, por el Lucro Cesante ocasionado por la resolución del contrato; **INFUNDADA** la pretensión en el extremo del Daño Moral solicitado.

OCTAVO. - DECLARAR FUNDADA la cuarta pretensión principal, en consecuencia, **SE ORDENA** a la Municipalidad Distrital de Huácar que asuma el pago de la totalidad de las costas y costos del proceso arbitral, **ORDENÁNDOSELE** el reembolso a favor del demandante en la suma de **S/ 16,000.00 (DIECISÉIS MIL CON 00/100 SOLES)**.

Disponer que en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles de emitido el presente Laudo Arbitral, la Secretaría Arbitral cumpla con notificarlo a las partes en sus respectivos domicilios procesales electrónicos. -

Firmado:


Abog. HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA
Arbitro Único


Abog. GABRIELA LUCERO ECHEVARRÍA TAFUR
Secretaría Arbitral